

DERECHO COMERCIAL I
DANIEL OCAMPO M.

Índice

Introducción.....	3
Fuentes del Derecho Comercial	4
I. Constitución política de la República.	4
1. El principio de Subsidiariedad	4
2. Principio de Igualdad ante la Ley	4
3. Derecho a asociarse sin permiso previo	5
4. Libertad de Empresa y Estado empresario	5
5. Interdicción de la arbitrariedad en sede económica	6
6. Derecho de Propiedad.....	6
6.1. Propiedad intelectual e industrial	6
II. La Ley.....	7
III. Costumbre.....	7
IV. Tratados y Convenios Internacionales	11
V. Disposiciones Administrativas	12
VI. Doctrina.....	12
El Acto de comercio	13
I. El carácter objetivo.....	13
II. Teoría de lo accesorio	13
III. Actos Mixtos o de Doble carácter	15
IV. La Mercantilidad esta fijada por la ley y no por las partes.....	17
Crítica a la teoría tradicional	17
Importancia de la distinción entre actos civiles y mercantiles	18
Análisis de los Actos de Comercio	22
I. La compra y permuta de cosas muebles, hecha con ánimo de venderlas,	22
II. La compra de un establecimiento de comercio.	23
III. El arrendamiento de cosas muebles hecho con ánimo de subarrendarlas.....	25
IV. La comisión o mandato comercial.....	26
Actos ejecutados por empresas	29
V. Las empresas de fábricas, manufacturas, almacenes, tiendas, bazares, fondas,.....	31
VI. Las empresas de transporte por tierra, ríos o canales navegables.....	34

VII. Las empresas de deposito de mercaderías, provisiones o suministros, las	35
VIII. Las empresas de espectáculos públicos, sin perjuicio de las medidas de policía	38
Actos formales de comercio	40
ADC fuera del artículo 3º del Ccom	45
Taxatividad de los ADC	46
El empresario	49
Elementos de la definición	50
Delegación de ejecución de actos o contratos	52
Efectos de la calidad de comerciante.....	53
Normas particulares sobre la capacidad.....	54
Comercios limitados para determinadas entidades	57
Obligaciones de los comerciantes	60
I. Llevar libros de contabilidad y de comercio.....	61
Principios de la contabilidad	63
Problema jurídico en cuanto a la contabilidad.....	66
II. Inscribir documentos en el registro de comercio	67
Documentos que deben inscribirse.....	68
III. Inscribirse en determinados registros.....	70
IV. Pagar patente municipal.....	71
Personal del empresario de comercio	72
El mandato comercial.....	76
Quienes pueden ser gerentes.....	79
Facultades del factor	79
Derechos del factor.....	80
Obligaciones del factor	80
Prohibiciones del factor	81
Termino del mandato	81
Mancebos o dependientes.....	84
Facultades de los mancebos	84
Situación de agentes independientes	85
Forma de hacer el encargo	86
Obligaciones del comisionista	86
Forma del cumplimiento	87
Derechos del comisionado	87
Extinción de la comisión.....	88

INTRODUCCIÓN

Pregunta prueba: caso practico. “como se soluciona” determinar si es o no un ADC, que legislación se aplica, como se regula, como se sanciona, quien es el obligado, etc.

Es la rama del derecho, que regula la actividad comercial y la de los sujetos activos que la ejercen o intervienen en ella. Esta actividad comercial se relaciona con los actos de comercio.

La mayoría de la doctrina y la jurisprudencia entiende que los actos de comercio que enumera el Ccom, es una enumeración taxativa. No hay mas actos de comercio que aquellos que se definen en el artículo 3° del Ccom. La gran mayoría de la doctrina y jurisprudencia reconocen esta taxatividad.

El profesor no cree que sean taxativos. Sino que es una enumeración meramente enunciativa.

El derecho comercial es un derecho absolutamente inherente de la persona humana. Desde siempre han existido las relaciones comerciales.

No vamos a ver la Historia del Derecho comercial. Nos remitimos a los siguientes libros:

1. Gonzalo Baeza Ovalle sobre historia del Derecho comercial en Chile.
2. Juan Esteban Puga.

Estos libros mencionan de donde viene el derecho comercial. Este llego a través de las ordenanzas de Bilbao, que provenían a su vez de las 7 partidas de Alfonso X el sabio. Desde esta época, se regulo el derecho comercial en Chile hasta llegar a la codificación. El Ccom, estaba listo y redactado en la misma época que iba a ser promulgado el Código Civil, vale decir, en 1855. Pero los civilistas hicieron que se atrasara 10 años. El redactor del Ccom es José Gabriel Ocampo Guerrero.

El sistema comercial tradicional produjo su cambio con la revolución francesa, y esto es lo que tomo el redactor del Ccom. Se implementa una visión objetiva y se eliminan la obligatoriedad de pertenecer a ciertos gremios para ejecutar actos de comercio. Esta visión objetivo es la que se adopta en el Ccom.

Así en el artículo 1° del Ccom, establece:

Artículo 1°. El Código de Comercio rige las obligaciones de los comerciantes que se refieran a operaciones mercantiles, las que contraigan personas no comerciantes para asegurar el

cumplimiento de obligaciones comerciales, y las que resulten de contratos exclusivamente mercantiles.

Por ende, se puede ejecutar un ADC sin llegar a ser comerciante. Por eso tenemos esta definición que nos da el Ccom, en cuanto rige las obligaciones de los comerciantes y de aquellas que no lo son.

Con esto nos adentramos en este concepto del derecho comercial, hacia donde estamos apuntando.

FUENTES DEL DERECHO COMERCIAL

Esto lo veremos de forma muy simple.

I. Constitución política de la República.

Esta CPR establece principios básicos en el derecho mercantil.

1. El principio de Subsidiariedad

Artículo 1º inc. 3º CPR, este inciso señala

“(…) Artículo 1.i3. El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos.”

Este principio es fundamental, porque si existe un régimen estatal de economía centralizada no hay derecho comercial, no existe el comercio como tal porque el comercio es la posibilidad de cada uno de hacer un negocio.

Se le debe perder el miedo a la palabra “lucro”. La gente quiere obtener utilidades, es lógico. El lucro es la ganancia que se obtiene por el ejercicio de la profesión o por un negocio o por un ADC, etc. Y ese lucro no es cuestionable o sancionable.

El lucro es malo cuando es ilegítimo. No puede existir comercio sin ánimo de lucro.

2. Principio de Igualdad ante la Ley

Artículo. 1º inc. 5, “Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de ésta, promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional.”

3. Derecho a asociarse sin permiso previo

Artículo 19 N°15: "...El derecho de asociarse sin permiso previo. Para gozar de personalidad jurídica, las asociaciones deberán constituirse en conformidad a la ley. Nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación. Prohíbanse las asociaciones contrarias a la moral, al orden público y a la seguridad del Estado."

Se habla del derecho de asociarnos, de constituir una sociedad. La finalidad de la constitución de una sociedad no es solo porque se quiere ejercer de manera eficiente el ADC, sino que hay implicancias tributarias, y de mayor posibilidad de ejercer todos los actos.

No solo se puede actuar como empresario individual. Porque si se tiene un negocio chico, no se necesita mas. Pero si uno se quiere establecer con una cadena y el negocio crece, se tendra que recurrir a socios, a prestamos, etc.

La posibilidad de que uno se pueda asociar, permite el desarrollo de los ADC.

Esto se relaciona con la libertad de trabajo, como así la libertad de ser contratado, que es un reconocimiento constitucional.

4. Libertad de Empresa y Estado empresario

Siguiendo una tradición republicana instaurada en 1811 con la declaración de "libertad de comercio" en Chile, en la actualidad el art.19 N°21 CPR garantiza a todas las personas:

"(...) El derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen.

El Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas solo si una ley de quórum calificado los autoriza, En tal caso esas actividades estarán sometidas a la legislación común aplicable a los particulares, sin perjuicio de las excepciones que por motivos justificados establezca la ley, la que deberá ser asimismo de quórum calificado..."

Es una garantía constitucional y pilar fundamental de nuestro sistema económico de economía social de mercado. La ordenación económica de nuestro país descansa en esta garantía constitucional. La garantía se relaciona con "desarrollar cualquier actividad económica".

Todos tenemos el derecho a ejercer nuestros ADC libremente, de forma individual o societaria. La falta de control del orden publico afecta el comercio.

En cuanto a los negocios que sean contrarios a la ley, es distinto porque la ley puede variar.

Hasta hace 3 semanas, era inconstitucional disponer de los fondos de las AFP, ahora si se puede. Todo va variando.

5. Interdicción de la arbitrariedad en sede económica

Se prohíbe ejercer las discriminaciones arbitrarias.

El art.19 N°22 contiene la siguiente garantía:

“(…) La no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica. Sólo en virtud de una ley, y siempre que no signifique tal discriminación, se podrán autorizar determinados beneficios directos o indirectos en favor de algún sector, actividad o zona geográfica, o establecer gravámenes especiales que afecten a uno u otras. En el caso de las franquicias o beneficios indirectos, la estimación del costo de éstos deberá incluirse anualmente en la Ley de Presupuestos...”

6. Derecho de Propiedad

El art.19 N°23 de la CPR garantiza: “La libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, excepto aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres o que deban pertenecer a la Nación toda y la ley lo declare así. Lo anterior es sin perjuicio de lo prescrito en otros preceptos de esta Constitución. Una ley de quórum calificado y cuando así lo exija el interés nacional puede establecer limitaciones o requisitos para la adquisición del dominio de algunos bienes;”

No puede haber comercio sin propiedad, si no hay propiedad con suerte puede haber una intermediación de bienes, pero no existe una actividad comercial sin este derecho.

Esto es así porque en el este derecho, se compra para vender, y uno se hace dueño de las utilidades, y se pueden invertir o reinvertir.

En las SA, todos los años se deben repartir al menos el 30% de las utilidades de cada ejercicio. Y se las reparten a los accionistas, o sea, no puede existir derecho comercial sin derecho de propiedad.

6.1. Propiedad intelectual e industrial

Aquí la propiedad no recae sobre un bien corporal o incorporeal, no se trata como un derecho sobre bienes corporales o incorporeales.

El art.19 N°25 de la CPR garantiza:

“(…) La libertad de crear y difundir las artes, así como el derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie, por el tiempo que señale la ley y que no será inferior al de la vida del titular. El derecho de autor comprende la propiedad de las obras y otros derechos, como la paternidad, la edición y la integridad de la obra, todo ello en conformidad a la ley. Se garantiza, también, la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la ley. Será aplicable a la propiedad de las creaciones intelectuales y artísticas y a la propiedad industrial lo prescrito en los incisos segundo, tercero, cuarto y quinto del número anterior…” (No se aplica al primero porque este habla del derecho de propiedad en su diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporeales.)

II. La Ley

El artículo 2° del Ccom dispone:

Art. 2°. En los casos que no estén especialmente resueltos por este Código, se aplicarán las disposiciones del Código Civil.

Es decir, la ley es fuente del derecho comercial y la principal ley en esta materia es el Ccom, pero en los casos que no estén regulador por este, se aplica las disposiciones del Código Civil.

Por su parte, el artículo 13° del Código Civil, las disposiciones de una ley relativas a casos o negocios particulares prevalecen sobre las disposiciones generales de la misma ley.

Es el principio de la especificidad, es decir, la ley particular prima o rige sobre la ley general. Y así ocurre en el derecho comercial, donde hay leyes que son absolutamente específicas.

Por ejemplo, en el Código Civil en la sociedad artículo 2056, esa es la sociedad colectiva civil, nosotros veremos todas las sociedades. Si uno se hace una sociedad colectiva civil por la responsabilidad ilimitada que tiene, serian los faraones. Porque no es recomendable a un cliente que haga una sociedad colectiva civil por la responsabilidad ilimitada. Se debe recomendar hacer una sociedad de responsabilidad limitada, o una SA, o SpA, o las Sociedades en un día.

III. Costumbre

La costumbre se preguntará en las evaluaciones.

Es totalmente distinta a lo que se estudia en derecho civil. Ya sabemos que el derecho comercial es un derecho eminentemente evolutivo, en la medida que ha ido desarrollándose el hombre en las actividades.

Surge este concepto de derecho comercial y se ha ido regulando. Por eso la costumbre cobra una relevancia que no tiene en otras ramas.

Para estos efectos, la costumbre es una conducta, publica, uniforme y reiterada en el tiempo (es decir, tiene un elemento objetivo), que ha sido aceptada por la colectividad en términos de atribuirle una eficacia jurídica como norma de derecho (también tiene un elemento subjetivo).

El elemento subjetivo es la *opinio iuris*, que son los 2 elementos que contiene la costumbre mercantil:

- 1º. El elemento objetivo: que es esta conducta uniforme, reiterada y permanente.
- 2º. El elemento subjetivo: Es elevada a la categoría de norma con fuerza vinculante, que es la *opinio iuris*.

De aquí surge la relevancia de la costumbre como fuente del derecho mercantil.

Art. 4º. Las costumbres mercantiles **suplen** el silencio de la ley, cuando los hechos que las constituyen son uniformes, públicos, generalmente ejecutados en la República o en una determinada localidad, y reiterados por un largo espacio de tiempo, que se apreciará prudencialmente por los juzgados de comercio.

Suplen el silencio de la ley, no es simplemente cuando la ley se remite a ella, acá la costumbre suple el silencio de la ley, o sea, esa es su principal relevancia.

Pero, además, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 6º del Ccom;

Art. 6º. Las costumbres mercantiles servirán de regla para determinar el sentido de las palabras o frases técnicas del comercio y para interpretar los actos o convenciones mercantiles.

Por ende, no solo suple el silencio, sino que sirven como elemento interpretativo para explicar los sentidos, alcances, palabras o frases técnicas del comercio, o interpretar actos.

Por ejemplo, el artículo 225 Ccom, establece que los pasajeros en el contrato de transporte:

Art. 225. Los pasajeros no están obligados a hacer registrar los sacos de noche, valijas o maletas que según la **costumbre** no pagan porte; pero si se entregaren a los conductores en los momentos de la partida, los empresarios quedan obligados a su restitución.

Esto significa que antes de que empezaran los temas de los aviones Low-cost, la gente dejaba las maletas y luego se iban al avión. Cuando se empezó a cobrar por las maletas, la gente se dio cuenta que era mas fácil llevar maleta de cabina. La costumbre era que no se cobrara por eso.

Por otro lado, el artículo 262 señala:

Art. 262. La precedente prohibición no comprende la ejecución de aquellos actos subalternos que según la costumbre del comercio se confían a los dependientes.

Es decir, la costumbre esta absolutamente presente. Y suple el silencio de la ley, cuestión que no ocurre en derecho civil.

En derecho civil, la costumbre es fuente del derecho cuando la ley se remite a ella. Son pocos los casos, uno de ellos esta en el artículo 1940 Código Civil, en cuanto se refiere al arrendamiento y señala que el arrendatario es obligado a las reparaciones locativas. Y se entiende como reparaciones locativas la que según la costumbre del país son de cargo del arrendatario. (por ejemplo, cuando se rompe una luz, etc.) Este es un caso de remisión de la ley civil a la costumbre.

Pero en derecho mercantil es distinto, aquí la costumbre suple el silencio. Alcanza una fuerza de precepto legal.

Requisitos para que la costumbre tenga validez y eficacia:

- 1º. Uniformidad: debe tratarse de una misma conducta ante semejantes circunstancias. Si no fuera así, no seria reconocido por la gente. Por ejemplo, en la compra de una maquinaria, en ninguna parte se dice que se debe entregar un manual del usuario, pero se entrega igual por costumbre. Esto es una misma conducta ante semejantes situaciones, es decir, todos actúan de una manera uniforme ante una misma situación. Se refiere al hecho común que se repite.
- 2º. Publicidad: esta secuencia de hechos que forma la costumbre deben ser ampliamente conocidos, universalmente (si se trata de una costumbre que se aplica internacionalmente), o bien, localmente (en el país).
- 3º. La generalidad en la ejecución: esto no dice relación con un elemento cuantitativo, no se habla de una cuantificación de personas que ejecutan, sino que frente a determinada situación comúnmente se ejecutan los mismos hechos. El hecho que sea general, quiere decir que ante una misma conducta se adoptan los mismos hechos o se reacciona de una misma manera. Es aquello que hacen las personas frente a ese hecho común. (La uniformidad es el hecho, y la generalidad es como se aplica frente a ese hecho.)
- 4º. La reiteración por largo espacio de tiempo: para que esta costumbre valga, debe estar repetida en un largo espacio de tiempo. No puede llegar y ser una cosa que ha ocurrido un pasa a veces, tiene que darse en el tiempo.

5°. Debe ser probada: para que la costumbre tenga eficacia jurídica y supla el silencio de la ley, debe ser probada y esta prueba esta latamente desarrollada en el artículo 5 del Ccom.

Art. 5°. No constando a los juzgados de comercio que conocen de una cuestión entre partes la autenticidad de la costumbre que se invoque, sólo podrá ser probada por alguno de estos medios:

En primer lugar, se dice “no constando a los juzgados de comercio”, de conformidad al artículo 45 del COT, los juzgados civiles verán las materias comerciales. No existen los juzgados de comercio propiamente tal en Chile.

En cuanto a los tribunales arbitrales, en Santiago existe la Cámara de Comercio que tiene el centro de arbitraje y mediación. ¿Podríamos entender que es un tribunal de comercio?, los arbitrajes son muy buenos en alguna medida, son rápidos y son eficientes, porque desocupan la jurisdicción ordinaria. Pero al mismo tiempo son jueces y se esta en discusión si pueden actualmente dictar medidas precautorias o cautelares, pero se tiende a pensar que no. Los juicios arbitrales son agradables donde los abogados se respetan. Hay distintos tipos de arbitraje, esta el mixto, el de derecho (que es igual que la jurisdicción ordinaria). El arbitraje mixto es mejor, porque la tramitación queda a discrecionalidad del juez y de lo que determinen las partes, pero el fallo es conforme a derecho. También esta el arbitro arbitrador o amigable componedor. (nota: si somos demandantes arrancar del arbitro arbitrador). La sentencia de un arbitraje o un laudo arbitral, es un fallo y es un equivalente jurisdiccional.

En segundo lugar, dice “sólo se puede probar”, redactado en términos imperativos:

1°. Por un testimonio fehaciente de dos **sentencias** que, aseverando la existencia de la costumbre, hayan sido pronunciadas conforme a ella;

2°. Por tres **escrituras públicas** anteriores a los hechos que motivan el juicio en que debe obrar la prueba.

En esas EP debe constar la costumbre invocada.

La existencia de la costumbre la prueba quien la invoca, en esto nos remitimos al principio general de la prueba de las obligaciones, del artículo 1698 del Código Civil.

En cuanto a estas sentencias, ¿Pueden ser interlocutorias o deben ser definitivas?, Las sentencias interlocutorias son las que fallan el incidente de un juicio y establecen derechos permanentes en favor de las partes o que sirven de base para la dictación de la sentencia definitiva. El artículo 158 del CPC, trata esto. La prueba de la costumbre puede hacerse a través de estas dos sentencias

que den testimonio fehaciente de la costumbre que se invoca. Debe tratarse de sentencia que estén confirmadas o ejecutoriadas.

Algunos aspectos de índole procesal aplicables a la costumbre: ¿Puede un tribunal que esta conociendo un caso comercial sobre una costumbre, fallar el caso invocando una costumbre que le consta al juez, pero que no ha sido invocada por las partes? Esto es parte de juicios civiles que se rigen por el principio dispositivo. La mayoría de los jueces dicen que no pueden fallar una causa invocando una costumbre que al juez le consta porque nadie se la ha alegado, y por ende el fallo estaría fuera de los límites de la discusión.

Sin embargo, el principio jurídico del "*iura novit curia*", que establece que el juez conoce el derecho y debe aplicarlo, aunque las partes no lo hayan invocado. No habría entonces un fallo de ultra petita o infracción a las normas que debe contener la sentencia en los términos de los artículos 170 y ss. del CPC. Este principio permitiría solucionar muchos problemas en primera instancia si se aplicase, pero los tribunales tienen el pánico de que sus sentencias sean casadas de ultra petita por haber fallado de esta manera.

Clasificación de la Costumbre

1. Costumbres según ley: Las establece el artículo 2º del Código Civil, cuando la ley se remite a ella.
2. Costumbres fuera de ley: En el caso del Ccom, cuando se puede probar.

Se discute acerca de la existencia de los usos y costumbres, ¿Cuál es la diferencia?, esta no en la repetición de hechos, sino por el elemento subjetivo, es decir, la *opinio iuris*.

IV. Tratados y Convenios Internacionales

Se suscriben contratos y TI con distintas entidades, los tratados se firman a nivel gubernamental, pero también están los convenios internacionales que van otorgando nuevas formas de creación de normas mercantiles.

Por ejemplo, los tratados de Libre Comercio. Nuestro país ha suscrito muchos tratados de Libre comercio, pertenece a muchas organizaciones. Todos estos pactos van regulando y determinando también nuestras normas de comercio.

Se estudiarán los Títulos de Crédito en este curso; letra de cambio, cheques y pagares. Que son los instrumentos de pago en todas las actividades comerciales. Todos ellos tienen una reglamentación internacional que se aplica en nuestro país.

En Chile tenemos la ley 18.092 sobre letras de cambio y pagares, pero esta ley no es sino una repetición de los principios genéricos del convenio de Basilea.

V. Disposiciones Administrativas

Son los actos del regulador, el comercio de los bancos por ejemplo es una actividad que esta regulada por el Ccom, los bancos ejecutan actividades absolutamente reguladas.

Los bancos además de estar regulados en la ley 18.046 de SA, además están regulados por la SBIF (CMF), asimismo todas las SA que están reguladas y transan en bolsa, están reguladas por la CMF.

Las superintendencias van creando estas normas. Esto también se relaciona con la Ley de emprendimientos.

VI. Doctrina

El derecho comercial, es absolutamente evolutivo. Va avanzando en la medida que van complejizándose las relaciones comerciales de las personas. A mayor nivel de complejidad se requieren nuevas soluciones y en ese sentido, los informes en derecho y comentarios o libros sirven de respaldo a nuestra pretensión doctrinal.

6 de agosto

Estuvimos hablando de las fuentes del derecho comercial. Dentro de las fuentes lo que más destacamos es la costumbre. La costumbre mercantil es relevante. Debemos saber qué es la costumbre, características, y cómo se prueba. La costumbre puede ser fuente del derecho comercial, y en materia mercantil suple el silencio de la ley.

Los actos de comercio están definidos en el Código del Comercio y han generado contradicciones. Nosotros tendemos a pensar que deberían haber más. No están establecidos en el artículo 3 del Código de Comercio los contratos nuevos o innominados, por ejemplo, la franquicia, contratos de suministro, entre otros. Sin embargo, no cabe duda que estamos frente a actos de comercio.

Se define el acto de comercio como la intermediación habitual de bienes que hace una persona con ánimos de lucro. Es una actividad habitual, es lo que hacemos en nuestro ejercicio de actividad profesional. El profesor Ocampos diría que es algo permanente. ¿Qué tipo de bienes se pueden intermediar? Bienes corporales e incorporeales. Si yo tengo, por ejemplo, un restaurante de comida rápida y es tan extraordinario que lo quiero vender, no solo voy a vender las mesas, cajas registradoras, sino que el establecimiento de comercio y además el derecho de llaves. Todo se puede vender, todo tiene un precio. ¿Puedo ejercer cualquier tipo de comercio? Claramente no, pensemos en el caso de la venta de órganos del cuerpo humano, drogas, prostíbulos, entre otros. Lo determinante es el ánimo del lucro, el ánimo de querer obtener

ganancia. Estamos hablando del comerciante que quiere obtener utilidades. Ganancias no es lo mismo que lucro. Las fundaciones, por ejemplo, están fuera del ámbito mercantil.

10 de agosto

EL ACTO DE COMERCIO

Intermediación habitual de bienes que hace una persona con animo de lucro.

La teoría del ADC descansa en 4 pilares fundamentales. Esta es la teoría tradicional, porque se critica mucho en la actualidad esta teoría, pero aun existe.

Pilares de los Actos de Comercio:

I. El carácter objetivo.

Es que solo la ley señala cuales son los ADC, es decir, existe una enumeración que es taxativa por parte del Ccom.

No existen otros ADC que aquellos que están establecidos en la ley. En jurisprudencia se habla mucho de la taxatividad del artículo 3ero del Ccom. Son solo aquellos que están establecidos en la propia ley.

Esta postura se critica. Algunos dicen que es una enumeración enunciativa.

II. Teoría de lo accesorio

Se pregunta en prueba.

Es un principio fundamental, y se puede definir como un efecto jurídico por el cual un acto que naturalmente no es comercial, pasa a quedar bajo la legislación comercial en razón de acceder a una obligación mercantil realizada por un comerciante en su giro, o para complementar su giro.

El propio artículo 1º del Ccom, señala que el código rige las obligaciones de los comerciantes y las que contraigan personas no comerciantes para asegurar el cumplimiento de obligaciones comerciales.

Por su parte el artículo 3ero del Ccom, cuando define la accesoriedad, señala que no son actos de comercio la compra o permuta de objetos destinados a complementar accesoriamente operaciones principales de una industria no mercantil.

Por ejemplo, si se compra 1 kg de harina para hacer pan, esa harina no la venderá quien la compra. ¿Es un acto civil o mercantil? Es un acto civil para quien lo compro sin que lo venda.

Pero resulta que si lo compro para vender, fabricar o intermediar con animo de lucro, ese acto pasa a ser mercantil. Esto es el principio de la accesoriedad.

Es decir, que un acto que no es naturalmente un acto mercantil, pasa a serlo si viene a complementar o accede a la obligación o al giro mercantil que pueda tener la persona que lo esta ejecutando.

Por ejemplo, si un escritor de libros (actividad civil), requiere comprar un camión para transportar sus cuentos y realiza la compra de un camión con factura y todo. ¿Es una obligación civil o mercantil?, sería una obligación más civil, porque no tiene un animo de lucrar, solo esta complementando una obligación civil.

Por ejemplo, si tengo un camión de transporte y además tengo un giro de transporte, soy transportista. Esa es una actividad absolutamente mercantil, y resulta que mientras voy en la carretera y paro a comprar o a echar bencina. ¿La compra de bencina es civil o mercantil? Si compro bencina para financiar el transporte, esa compra es mercantil, porque complementa la actividad de transporte y el transporte es una actividad mercantil, por tanto, como lo accesorio sigue la suerte de lo principal, tengo absoluto derecho a que me emitan una factura, y descontar este gasto necesario para producir la renta.

Ahora si pase a echar bencina porque voy en el camión, pero en el camión no van los trabajadores sino que voy de vacaciones con la familia, y paso a echar bencina, eso ya no es una actividad que este complementando mi giro principal y ya no seria accesorio. Por eso la propia ley es la que dice que se sigue la suerte de lo principal.

Por tanto, una actividad que naturalmente no era mercantil puede llegar a serlo si complementa una actividad mercantil. Hay que atender al animo de lucro, y como el animo de lucro es un concepto de hecho que tenemos que analizar, en el fondo lo que se debe analizar es que pasa con la actividad principal que se ejerce.

Conforme a esto, los actos realizados por comerciantes en el desarrollo de su actividad profesional son ADC por accesoriedad, en tanto aquellos que se hacen para la vida privada, es decir, para la vida civil, se mantienen como actos civiles.

Luego, esto importa para distinguir los efectos de estar frente a un acto mercantil o civil.

Por ejemplo, tengo mi propia empresa, ¿si me compro un auto a titulo personal, lo puedo incluir como una actividad mercantil por ser parte de mi giro?. Hubo una época, en la que se estableció por parte del SII que se podían comprar autos para las empresas y se podía descontar porque se veía como un gasto necesario para producir la renta. Y la importancia de eso era que se podía descontar de la base imponible, y se hacia pasar el auto como gasto. Y mucha gente de la

industria forestal se permitía comprar estos autos grandes, entonces el SII dijo que ya no se podía y que si se quería comprar un auto para la empresa, se debía poner los logos de la empresa.

La teoría de lo accesorio nos permite siempre atender si el acto será civil o mercantil, si es que viene a complementar nuestra actividad principal.

Si mi actividad principal es civil, se mantiene el acto civil. Si es mercantil, se mantiene el acto mercantil.

III. Actos Mixtos o de Doble carácter

Esto tiene que ver con que las relaciones comerciales pueden hacer que un mismo acto sea mercantil y civil al mismo tiempo, según quien fueran las partes.

Por ejemplo, va una persona y compra harina porque quiere hacer un pan. Esa actividad para quien compra es civil porque quiere comer el pan, pero para el panadero es una actividad mercantil, porque él esta ejecutando su giro.

Es decir, un acto puede ser al mismo tiempo comercial o civil, según quien fuere el agente que lo ejecuta.

Por ende, el principio de la accesoriedad y del acto mixto, van muy unidos.

El inciso 1 del artículo 3 del Ccom, establece que "Son actos de comercio, ya de parte de ambos contratantes, ya de parte de uno de ellos:"

Es la propia ley quien reconoce la existencia de que un ADC puede tener este doble carácter.

Ahora, ¿Cómo se soluciona el conflicto?. Resulta que la harina salió mala. ¿Bajo que ley se demanda?, bajo la LPC. Pero, ¿Qué hace el juez?, para solucionar esto se regula la ley del **obligado**.

Así se determina que se debe fallar, es decir, cuando existe un conflicto jurídico que involucra una parte civil y una mercantil, hay que aplicar la ley del obligado. Es decir, se debe estar atento a cual es la pretensión para determinar la norma que resolverá la Litis.

Si el acto es mercantil para el demandado, se tendra que resolver conforme al derecho mercantil. Si el acto es civil para el demandado, se resuelve conforme el derecho civil. El obligado es la ley que esta demandada.

Actos de comercio formal

Sin embargo, existen también los que se denominan dentro de esto, los actos de comercio formal.

Los actos de comercio formal son aquellos que son siempre mercantiles, con independencia de quien los ejecute o cual fuere su actividad principal. Independiente si los ejecuta un comerciante o una persona civil.

Son actos absolutamente mercantiles y siempre son así. Mercantilizan todas las relaciones y se rigen y sancionan conforme a la ley mercantil.

Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con:

- Operaciones de bancos
- Letras de cambio
- Pagares
- Cheques

Es muy común y cada día mas en desuso, el giro de cheques. Antes de que existiera la posibilidad de hacer transferencias o depósitos, el cheque era una maravilla.

Resulta que por ejemplo, un señor viene a su casa y hace una instalación de unos cuadros, y se le paga con un cheque. Quien paga es abogado y no es comerciante, seria un acto mercantil, porque es un acto formal de comercio.

Hay algunas normas que presumen mercantilidad, como la ley 18.046 de SA que establece en el inciso 2do del artículo 1º que la SA es siempre mercantil aun cuando tenga por objeto negocios civiles. ¿será siempre mercantil una empresa?

Art. 1º La sociedad anónima es una persona jurídica formada por la reunión de un fondo común, suministrado por accionistas responsables sólo por sus respectivos aportes y administrada por un directorio integrado por miembros esencialmente revocables.

La sociedad anónima es siempre mercantil, aun cuando se forme para la realización de negocios de carácter civil.

Si una SA ejecuta un acto que no es calificado como ADC, ¿responde como sujeto mercantil?

¿Puede una SA ejecutar actos civiles?, si. Tenemos que atender a cuál es el acto que se ejecuta. La CS atiende a si existe o no un acto mercantil más alla de si esta constituido o no como una persona civil o mercantil. Se debe ver el acto.

Ejemplo, si me quiero operar la guata o nariz, ¿que acto es? Es un acto civil porque la ley no contempla las operaciones medicas como actos mercantiles.

Por ende, para estar frete a un ADC lo primero que debemos atender es a si lo establece la ley, si el acto de comercio esta establecido dentro de los 20 numerales que establece el artículo 3, es un ADC.

IV. La Mercantilidad esta fijada por la ley y no por las partes

Por tanto, es irrelevante que las partes califiquen un acto como mercantil, pues la comercialidad es un asunto de derecho y no de hecho. Es irrelevante que las partes determinen si un acto es mercantil o no.

Quien aprecia si algo es o no mercantil, es el juez. La mercantilidad no depende de la voluntad de las partes.

Por ejemplo, caso de Colo-colo. En este fallo se declara la quiebra del ex presidente de la corporación de colo-colo, y asumió la liquidación un sindico. se pide la quiebra del presidente porque el firma una declaración en una EP, como factor de comercio. Y por ende se declaro la quiebra de esta persona como deudor comerciante. Lo que hace la corte es dejar sin efecto esa declaración de quiebra.

Este es el ultimo pilar fundamental de la teoría del acto de comercio. La mercantilidad no depende de lo que digan las partes.

Entonces ¿Cómo se resuelve un conflicto sobre que legislación se aplica? Lo primero que hay que hacer es determinar si el acto esta o no dentro de aquellos que la ley establece como ADC, si no esta, estamos liberados.

Si es un ADC, tendremos que distinguir si esta dentro de los principios de que pueda considerarse un acto accesorio, o un acto mixto, o bien puede tratarse de un acto formal de comercio.

CRITICA A LA TEORÍA TRADICIONAL

Libro de Juan Esteban Puga. Se critica a estos pilares;

- 1º. Primero porque no podemos estar frente a un ADC cuando el propio código establece que hay que distinguir si puede ser para una o ambas partes. O sea el hecho mismo de que exista un acto mixto hace caer a la teoría tradicional.
- 2º. En segundo lugar, tampoco podemos hablar de los principios de un acto mixto, cuando la propia ley establece los actos formales. Es decir, si es el propio legislador el que establece que existe actos formales de comercio, no puede recaer en las partes la obligación o el peso probatorio de determinar si lo son o no.

- 3º. En lo que si esta de acuerdo, es en el ultimo pilar, es que la mercantilidad es una cuestión que aprecia el juez y da lo mismo lo que las partes digan.
- 4º. Por ultimo, se critica la enumeración de los ADC porque por ejemplo el artículo 3º N°5 Ccom, dice: " 5º. Las empresas de fábricas, manufacturas, almacenes, tiendas, bazares, fondas, cafés y otros establecimientos semejantes."

Dice "las empresas", ¿una empresa puede ser un Acto Jurídico? NO.

Una empresa ¿puede estar constituida por una sola persona?, si. Entonces no es necesario que sea una persona jurídica. No se debe confundir el concepto de empresa con persona jurídica, porque puede ser una empresa formada por una persona natural.

Una persona jurídica, es un ente ficticio. No existe en la realidad. Pero es una persona capaz de generar derecho y obligaciones. Puede ser sujeto de derecho. Tienen los mismos atributos de la personalidad que las naturales, salvo el estado civil.

Cuando la ley habla de empresas, no solo se refiere a estos entes ficticios, sino que también a una persona. Y una persona puede ser empresario sin estar constituido en algún tipo de sociedad. Si no quiero tener una empresa con alguien, la ley me permite ser un empresario individual y no estar asociado con alguien.

Se critica finalmente la teoría tradicional del ADC porque dice que son ADC las empresas, y estas empresas bien sea 1 personas o un grupo de personas, una empresa no es un ADC. Podrá celebrar ADC, pero no es uno.

IMPORTANCIA DE LA DISTINCIÓN ENTRE ACTOS CIVILES Y MERCANTILES

Porque hay normas que son particulares de cada uno. Antiguamente en la Ley de Quiebras vigente hasta octubre del 2014.

Establecía el artículo 41 de esa ley, que todo deudor dedicado a una actividad comercial, industrial, agrícola o minera, debía pedir su propia quiebra dentro de los 15 días siguientes de que había cesado en el pago de una obligación mercantil.

La sanción, es que si no lo hacían, podía ser declarado como quiebra culpable o dolosa. Entonces esa era la importancia.

Como se derogo la ley de quiebras y entro a regir la ley de insolvencia y re-emprendimiento. Se derogo entonces el artículo 41 y la doctrina decía que daba lo mismo la distinción del ADC actualmente, ya que no servía para nada porque no estaba el artículo 41 de la Ley de quiebras.

Sin embargo, no es así. Hay varias cosas importantes aun. Por ende no se ha perdido la importancia entre distinguir entre una actividad civil o mercantil.

1º. Primero porque sirve para determinar cual es la legislación aplicable.

Porque el Ccom establece una cosa que se llama “la C-V mercantil”, que comparte mucho de lo que establece la C-V civil. Pero también el Código Civil, establece la sociedad en el artículo 2056. El Código Civil, establece la sociedad colectiva, pero es una sociedad con responsabilidad ilimitada, los socios responden ilimitadamente y con todo su patrimonio de las obligaciones sociales. Se hace plenamente efectivo el artículo 2465 del Código Civil, es decir, el derecho de prenda general. Esto no es conveniente para los clientes, sino que se debe ver la legislación aplicable. Y en el Ccom se establece la misma sociedad colectiva pero con responsabilidad limitada, que es lo mas recomendable para los clientes.

Entonces la primera importancia de distinguir entre estos actos, es para ver la legislación aplicable.

2º. En segundo lugar, es importante respecto de los medios de prueba.

El Ccom establece reglas probatorias especiales distintas a las que se establecen en materia de derecho civil.

Por ejemplo, la prueba testimonial en materia civil es distinta que la prueba instrumental. Pero hay cosas que no se pueden probar con testigos en materia civil, específicamente el artículo 1708 del Código Civil señala que no se admitirá la prueba de testigos respecto de una obligación que haya debido consignarse por escrito. Y el artículo 1709 dice que deberán constar por escrito los actos o contratos que contengan la entrega o promesa de una cosa que valga mas de 2 UTM, menos de 100 mil pesos. La prueba testimonial esta limitada en materia civil.

Sin embargo, el artículo 128 del Ccom, señala que la prueba de testigos es admisible en negocios mercantiles, cualquiera que sea la cantidad que importe la obligación que se trate de probar. Salvo cuando la ley exige EP. En materia mercantil, se puede probar por testigos.

- 3°. En tercer lugar, tiene importancia por la validez de los instrumentos privados.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 1704 del Código Civil respecto a la prueba instrumental, los asientos, registros y papeles domésticos únicamente hacen fe contra quien los ha escrito o formado. Estamos hablando de documentos privados. Básicamente los arts. 1702 y 1704 señalan que los instrumentos privados para tener validez en juicio tienen que estar por reconocidos (346 CPC). Los instrumentos privados son aquellos que no son EP, y estos instrumentos tienen solo fuerza probatoria en la medida que sean reconocidos en el juicio o que no sean impugnados.

Pero en materia mercantil, los instrumentos privados hacen plena prueba respecto de los juicios entre comerciantes.

El artículo 35 del Ccom, dice “Art. 35. Los libros de comercio llevados en conformidad a lo dispuesto en el artículo 31, hacen fe en las causas mercantiles que los comerciantes agiten entre sí.” Es decir, hacen plena prueba.

Los libros de contabilidad son privados, no instrumentos públicos. Por ende si nos fuéramos a la esfera del derecho civil, tendrían que estar reconocidos y no objetados. Pero en materia comercial, los libros de contabilidad hacen plena prueba en juicio, tanto en favor como en contra.

Esto es así porque la contabilidad es una obligación de todos los comerciantes. Si tenemos un cliente que es comerciante, lo primero que debemos decirle es que lleve bien la contabilidad.

El SII dice que si uno es una empresa mediana o chica, no contrate contadores, porque el SII lleva la contabilidad. La contabilidad debe ser bien llevada.

En el mensaje del Ccom se señala que el proyecto considera la contabilidad como el espejo en que se refleja la conducta del comerciante, el alma del comercio de buena fe.

- 4°. En cuarto lugar, tiene importancia por la Ley de Protección al Consumidor 19.946.

Esta tiene plena aplicación cuando se trata de un consumidor civil y cuando el empresario o proveedor es mercantil, no existe protección de ley del consumidor en juicio entre comerciantes, porque esta ley supone que hay un proveedor y un consumidor final.

De ahí también la importancia de la distinción.

- 5°. En quinto lugar, tiene importancia por la costumbre.

En materia civil, la costumbre solo tiene validez cuando la ley se remite a ella. En cambio en materia mercantil suple el silencio de la ley.

6°. Finalmente, tiene importancia por la prescripción.

El tiempo de prescripción en materia civil, de conformidad a lo dispuesto al Código Civil la prescripción en las obligaciones es de 5 años en la acción ordinaria y 3 años en la ejecutiva. Cualquier tipo de obligación entonces, será de 5 años contados desde que la obligación se hace exigible. Además hay algunas prescripciones de corto plazo.

Sin embargo, el Ccom en el artículo 822 establece que; “Art. 822. Las acciones que procedan de las obligaciones de que trata el presente Libro y que no tengan señalado un plazo especial de prescripción, durarán cuatro años. Las prescripciones establecidas en este Código corren contra toda clase de personas.”

Es decir, en materia comercial prescriben 1 año antes que las obligaciones del derecho civil.

13 de agosto

La ley no define lo que son los actos de comercio, sino que los enumera. Opto por hacer esta enumeración y no definirlo para no dejar algunos afuera. Los actos de comercio se pueden clasificar en:

- Actos civiles o mercantiles atendiendo la intención con la que se ejecuten
- Actos que son ejecutados siempre por una empresa
- Actos que siempre son mercantiles o actos formales
- Actos mercantiles en razón de su objeto

El artículo 3 del Código de Comercio establece que: “Son actos de comercio, ya de parte de ambos contratantes, ya de parte de uno de ellos:

- 1) La compra y permuta de cosas muebles, hecha con ánimo de venderlas, permutarlas o arrendarlas en la misma forma o en otra distinta, y la venta, permuta o arrendamiento de estas mismas cosas. Sin embargo, no son actos de comercio la compra o permuta de objetos destinados a complementar accesoriamente las operaciones principales de una industria no comercial.
- 2) La compra de un establecimiento de comercio.
- 3) El arrendamiento de cosas muebles hecho con ánimo de subarrendarlas.
- 4) La comisión o mandato comercial.
- 5) Las empresas de fábricas, manufacturas, almacenes, tiendas, bazares, fondas, cafés y otros establecimientos semejantes.

- 6) Las empresas de transporte por tierra, ríos o canales navegables.
- 7) Las empresas de depósito de mercaderías, provisiones o suministros, las agencias de negocios y los martillos.
- 8) Las empresas de espectáculos públicos, sin perjuicio de las medidas de policía que corresponda tomar a la autoridad administrativa.
- 9) Las empresas de seguros terrestres a prima, incluidas aquellas que aseguran mercaderías transportadas por canales o ríos.
- 10) Las operaciones sobre letra de cambio, pagarés y cheques sobre documentos a la orden, cualesquiera que sean su causa y objeto y las personas que en ella intervengan, y las remesas de dinero de una plaza a otra hechas en virtud de un contrato de cambio.
- 11) Las operaciones de banco, las de cambio y corretaje.
- 12) Las operaciones de bolsa.
- 13) Las empresas de construcción, carena, compra y venta de naves, sus aparejos y vituallas.
- 14) Las asociaciones de armadores.
- 15) Las expediciones, transportes, depósitos o consignaciones marítimas.
- 16) Los fletamentos, seguros y demás contratos concernientes al comercio marítimo.
- 17) Los hechos que producen obligaciones en los casos de averías, naufragios y salvamentos.
- 18) Las convenciones relativas a los salarios del sobrecargo, capitán, oficiales y tripulación.
- 19) Los contratos de corredores marítimos, pilotos lemanes y gente de mar para el servicio de las naves.
- 20) Las empresas de construcción de bienes inmuebles por adherencia, como edificios, caminos, puentes, canales, desagües, instalaciones industriales y de otros similares de la misma naturaleza”.

ANÁLISIS DE LOS ACTOS DE COMERCIO

El Ccom opto por hacer una enumeración. Esta enumeración es taxativa, según lo reconoce toda la doctrina y jurisprudencia.

- I. La compra y permuta de cosas muebles, hecha con ánimo de venderlas, permutarlas o arrendarlas en la misma forma o en otra distinta, y la venta, permuta o arrendamiento de estas mismas cosas.

Sin embargo, no son actos de comercio la compra o permuta de objetos destinados a complementar accesoriamente las operaciones principales de una industria no comercial.

Respecto al primer numeral, es relevante que se excluyen los inmuebles. Si yo me compro un departamento, y tiene fallas de construcción, ¿cuál será la legislación aplicable? La legislación aplicable es civil, porque están excluidos los inmuebles. Se requiere una intencionalidad mercantil. El elemento subjetivo es determinante. Tiene que haber ánimo de venderlo,

arrendarlo o permutarlo Si yo no tengo la intención es evidente que no estamos frente a un acto de comercio. Se consagra la teoría de lo accesorio. Esto tiene relevancia en materia de impuestos.

II. La compra de un establecimiento de comercio.

El numeral segundo establece la compra de un establecimiento de comercio. ¿Qué podemos entender por este concepto? Es una universalidad de derechos integrada por bienes muebles e inmuebles, corporales o incorporeales que fueron organizados por el comerciante para el desarrollo de su actividad. Hay un comerciante que para efectos de llevar a cabo de su comercio se ha organizado y ha organizado una serie de bienes, muebles e inmuebles, corporales o incorporeales. Cuando nosotros efectuemos la compra de un establecimiento de comercio, siempre hay que hacer un inventario de lo que se está incluyendo. ¿Qué pasa con la venta? No, debido a que la ley solo establece la compra.

Cuando hablamos del artículo 3 N°2 que habla del establecimiento de comercio, que era una universalidad de derechos integrada por bienes muebles o inmuebles que fueron organizados por el comerciante para el ejercicio de su profesión.

El concepto de deuda también se incluye en la venta,.

17 de agosto

Pero ¿Qué pasa con las deudas? Las deudas forman parte de una empresa. Pero ¿son buenas o malas?

Por ejemplo, un caso de laboratorio. Un banco debe hacer un análisis de crédito entre dos personas, resulta que una de las personas, no tiene deudas, es mas no tiene ni cuenta corriente porque guarda la plata en el colchón, ya que es muy temeroso. Por otra parte, la otra persona ha pedido un crédito de consumo rápido, (estos de plata en pagare de máximo de 80 cuotas), además un crédito hipotecario, un crédito automotriz. Asi las cosas, esta ultima persona es un cliente del banco que tiene 3 productos asociados a su nombre. En cambio, la otra persona no tiene ninguno. ¿Quién será mejor cliente para el banco?, la persona con créditos.

La deuda no es mala, lo que se debe evitar es tener deuda vencida o morosa. El sobreendeudamiento es malo.

¿Qué le pasa al gran problema de las pymes? Son el 80% del movimiento empresarial nacional y todas se quejan de endeudamiento. Pero mas que el sobreendeudamiento, no saben servir o programar las deudas mensuales.

Por ejemplo, si pido un crédito, en este minuto están los famosos créditos Covid, pero resulta que yo pido 10 millones de pesos que lo tengo que pagar en 10 cuotas mensuales de 1 millón de pesos.

Con 1 millón yo hago toda mi estructura y flujo de empresa. El problema está en que no voy a pagar 1 millón de pesos, porque si pido un crédito debo pagar intereses, y además como el crédito Codiv es un crédito que viene con garantía del estado, que es un crédito fogafo, tengo que pagar una comisión equivalente a un 2% del valor de garantía que tiene ese crédito. Es decir, ya no pago cuotas de 1 millón, sino que estaré pagando 1 millón y 70 mil pesos. Y como no tenía contemplado pagar ese extra al tercer mes, ya no podré pagar la cuota siguiente.

El problema que tenemos con el concepto de deuda es que se le tiene miedo, pero la deuda no es mala.

Otro ejemplo, tengo un negocio de pollo a las brasas y me quiero comprar un carrito de delivery. Me compro una moto, que cuesta 2 millones. Si yo tengo los 2 millones de pesos en el bolsillo y compro esa moto, estoy perdiendo capital, porque estoy sacando de mi bolsillo 2 millones para comprar algo. Es más fácil ir al banco y hacer un leasing y el banco será quien compra la moto y me la arrienda a mí. Claro que es caro, porque en vez de pagar 2 millones pagare 2 millones y medios, pero los estaré pagado en cuotas mensuales que más encima puedo rebajar de las utilidades como gastos general para la base imponible de los impuestos.

El problema es no saber servir regularmente la deuda. En el lenguaje de la banca se dice "ahorquillado", para referirse a que no tiene solvencia.

Es bueno recurrir al financiamiento externo, bien sea de la banca, empresas de leasing, leasing financiero, leasing operativo, etc.

Por ejemplo, tengo una empresa constructora. Estoy levantando un edificio de 5 pisos. Para hacer esa construcción necesito una torre. Pero no me voy a comprar una grúa. La voy a arrendar. Eso es invertir en deuda. Y si tuviera que comprarla lo hago con financiamiento externo.

El negocio de los bancos, es que el usuario no logre pagar el total de la deuda. Si gasto por ejemplo en supermercado 200 mil pesos mensuales y el día 30 que es el día en que se produce el cierre de mi tarjeta pago los 200 no genero interés y aprovecho el crédito que me da la tarjeta. Pero lo que pasa es que las empresas que obviamente han hecho estos estudios, saben que la gente no paga los 200 mil porque la mentalidad de los chilenos es pagar la mitad y después ponerse al día. Y esa deuda ahí empieza a devengar intereses leoninos.

Ahora bien, cuando hacemos la venta de este establecimiento de comercio, se va a vender, obviamente también se incluyen las deudas, y en ese caso si tengo por ejemplo un crédito que lo estoy vendiendo, necesito el acuerdo del propio acreedor. Porque la figura que hay si se cambia

a una persona por la otra es la novación. Aquí hay una novación, que es un modo de extinguir las obligaciones entre el banco y el cliente, porque asume un nuevo deudor. Y la novación requiere esta aceptación que es el animus novandis.

Lo relevante es que se pueden vender las deudas. ¿Quién querría comprar una deuda?, mucha gente porque arrastran créditos fiscales tremendos.

Por ejemplo, si en mi empresa tengo pérdidas, le debo plata a todo el mundo. Y resulta que una persona con su empresa que tiene muchas utilidades. Pero ahí llega el asesor tributario, (contador), y dice que se tendrán que pagar muchos impuestos. Y entonces, si solo tengo utilidades ¿Qué hacemos?, compramos a la empresa que tiene pérdidas. El negocio no es tan malo, porque la empresa que tiene pérdidas puede tener un valor contable de mil millones de pesos, pero como solo esta con pérdidas, puede llegar la persona de la otra empresa que tiene utilidades y le ofrece 200 o 300 millones de pesos de los mil millones. Si la empresa que tiene pérdidas esta muerta, en el fondo lo que pasa es que le entran 300 millones de pesos que antes no tenia.

Por otro lado, lo que la empresa con utilidades hace es comprar mil millones de pérdidas, y si además antes tenia mil millones de utilidades y ahora tiene mil millones de pérdidas, como se fusionaron las empresas ya no tiene utilidades porque es una misma empresa. Ahora quedo en 0 utilidades y no paga impuestos.

Esto es un análisis contable que se debe hacer en una empresa para ver si conviene o no. Porque esto supone que ya se retiraron las utilidades y ya se hizo el reparto de dividendos. Además conforme a nuestro sistema tributario, uno paga impuestos conforme a las utilidades generadas, no las percibidas.

Tener deudas es bueno porque me da solvencia. En la teoría uno no debe estar endeudado mas alla del 33% de sus ingresos. Sobre eso es malo.

III. El arrendamiento de cosas muebles hecho con ánimo de subarrendarlas.

El tercer acto de comercio es el arrendamiento de cosas muebles hechas con ánimo de subarrendarlas. Un ejemplo podría ser transporte al aeropuerto. Una persona no va a gastar tanta plata de contado en autos, sino que va a una empresa de leasing. Esa empresa va a arrendarle y la persona lo subarrienda a distintos conductores. El leasing es un contrato de arrendamiento con opción de compra.

Nuevamente nos encontramos con un elemento subjetivo, que es el animo de sub arrendar.

Por ejemplo, una empresa que toma un leasing automotriz, va a adquirir 4 taxis que a si vez se los subarrienda a 4 choferes.

Nuevamente nos encontramos con dos cosas importantes:

- a) Los inmuebles siguen fuera: Los arrendamientos de inmuebles aun cuando se hagan con empresas de leasing son actos civiles.
- b) Debe existir un animo de una persona para subarrendarlo a otras.

Para ver si para las personas a quienes se les arrienda es un acto civil o mercantil se debe ver si complementa su actividad principal. Esto siempre se debe analizar bajo el prisma de la teoría de lo accesorio y del acto mixto.

IV. La comisión o mandato comercial

El mandato mercantil es muy parecido al mandato civil, se le encarga a una persona el cumplimiento o ejecución de algo.

El mandato mercantil, sin embargo, tiene una existencia propia y esta definido de manera propia en el Ccom.

Artículo 233 Ccom, Art. 233. El mandato comercial es un contrato por el cual una persona encarga la ejecución de uno o más negocios lícitos de comercio a otra que se obliga a administrarlos gratuitamente o mediante una retribución y a dar cuenta de su desempeño.

Se encarga la ejecución de 1 o mas negocios lícitos de comercio. Acá ya tenemos clara la diferencia entre el mandato civil y mercantil. El ultimo recae sobre ADC.

¿Podemos dar un mandato para casarnos? Si, pero no es un ADC.

Para celebrar cualquier tipo de ADC podemos otorgar este mandato mercantil.

Comisión: Ahora el mandato toma el nombre de comisión cuando se refiere a una o mas operaciones mercantiles determinadas.

Se puede dar un mandato general, que seria mercantil, pero si es un mandato para celebrar uno mas actos absolutamente determinados, pasa a tener el nombre de comisión mercantil.

Por ende, si el mandato es general, se denominará mandato, pero si es para actos determinados es comisión.

Parte de la doctrina (Palma, Sandoval) señala que para el mandante siempre este mandato mercantil será mercantil, y no podría entenderse de otra manera, mientras que para el mandatario, podría ser civil o mercantil según la teoría de lo accesorio.

Sin embargo, para doctrinas mas modernas, por ejemplo, para Jequier, el acto puede ser civil o mercantil tanto para el mandante como mandatario. Es independiente y hay que considerar la naturaleza del acto mismo.

Es decir, un agente civil puede celebrar un ADC, puede darle un mandato mercantil a una persona igualmente civil. No tengo que ser necesariamente un agente comercial para otorgar un mandato mercantil.

Por ejemplo, soy un escritor y quiero vender libros y le doy un mandato a alguien para que vaya a una empresa de leasing y arriende un bien mueble con el animo de subarrendarlo, es decir, con todas las ganas de efectuar un acto comercial. Ese mandato será mercantil porque va a celebrar un ADC. Pero si la persona a quien le di el mandato es una persona natural que también es poeta, el acto seguirá siendo mercantil y el mandato también. Pero esas personas seguirán siendo agentes civiles.

Entonces para determinar cual será la ley aplicable se debe ver si complementa la actividad principal mercantil o bien si se trata de un acto netamente mercantil.

Diferencias entre el mandato mercantil y civil

1. **En cuanto a la extinción.** El artículo 240 del Ccom, establece que el mandato mercantil no se extingue por la muerte del mandante. Art. 240. La comisión no se acaba por la muerte del comitente: sus derechos y obligaciones pasan a sus herederos. Mientras que para el mandato civil, si se extingue por la muerte del mandante, en virtud del artículo 2163 Código Civil.
2. **En cuanto a la posibilidad de poder delegar el mandato.** El artículo 261 del Ccom establece que el mandatario no puede delegar, salvo autorización expresa del mandante. Por su parte, el artículo 2135 del Código Civil señala que el mandatario puede delegar a menos que se le haya prohibido.
3. **En cuanto a la revocación del mandato.** El mandato comercial conforme lo establece el artículo 241 del Ccom, no se puede revocar cuando sede en beneficio del tercero, por ende el mandato cuando cede en beneficio de un tercero es irrevocable. En cambio, el mandato civil el artículo 2165 puede revocarse al solo arbitrio del mandante. Esto es muy importante.

Importancia: por ejemplo, si tengo una tarjeta con alguna casa comercial o un banco, se firma un contrato de cuenta corriente. En ese contrato se establece que se van a utilizar 3 tipos de productos; la cuenta corriente, la línea de sobregiro y la tarjeta de crédito. La cuenta corriente en general es para poder tener plata. Resulta que reviento la tarjeta de crédito, porque me bajo la locura y me compre 25 computadores. Si mi tarjeta tenia un cupo de 5 millones y gaste 4 millones 600. ¿Cómo me lo van a cobrar?. Porque resulta que como la tarjeta esta asociada a un contrato de la cuenta corriente van a ver si tengo

plata en esa cuenta y si la tengo, la tarjeta va a sacar la plata para pagar. Pero imaginemos que no teníamos cuenta corriente, que la línea de crédito o sobregiro la tenía sobrepasada y gaste 4 millones 800 mil pesos en tarjeta de crédito.

El banco lo que hace es ejecutar, ¿pero como me ejecuta si no he firmado ningún pagare? ¿Cómo me van a cobrar?, Lo que pasa es que en el contrato hay unas condiciones y términos. En una parte del contrato dice que le otorga un mandato mercantil e irrevocable al banco, para suscribir pagares por todas las deudas que pudiere tener con ocasión de los productos al cierre de la vigencia de la cuenta.

Es decir, el banco me va a cerrar la cuenta y va a proceder a llenar un pagare porque tengo un mandato.

Por ende, no se puede oponer frente a un tribunal una excepción de nulidad de la obligación por extralimitación del mandato. Eso no se puede porque se otorga un mandato mercantil e irrevocable en los términos del artículo 241 del Ccom al banco y lo que hace el banco es llenar el pagare.

Es mas, muchas casas comerciales, que son las empresas tipo Falabella, Ripley, lo que hacen es que uno les da un mandato a estas empresas, pero en el fondo no les dan el mandato ni a Falabella ni a Ripley, en el caso de Falabella le dan un mandato a una empresa que se llama CMR, para llenar los pagares, en el caso de Paris a Card administradora de créditos. O sea, mas encima el mandato se lo estoy dando a un tercero.

El mandato mercantil es el que se utiliza en toda la esfera comercial.

4. **En cuanto a la renuncia.** De conformidad a lo dispuesto en los artículo 245 del Ccom, el comisionista o mandatario no puede renunciar sin una causa legal que lo legitime, porque esta ejecutando ADC y el comercio importa a los terceros. En cambio en el mandato civil conforme al artículo 2163 y ss. , puede renunciar sin perjuicio de tener que responder por los perjuicios que pudiere causar al mandante, pero puede renunciar.
5. **En cuanto a la auto contratación.** En materia mercantil conforme al artículo 271 Ccom, el comisionista no puede auto contratar, no puede celebrar un acto consigo mismo en representación del comitente, salvo que este lo autorice expresamente, es decir, no puede auto contratar a menos que haya sido autorizado. En cambio, en el mandato civil, no existe una prohibición general para la auto contratación, salvo las excepciones legales, el artículo 2144 Código Civil establece que el mandatario no puede comprar para si lo que se le ha ordenado vender ni vender de lo suyo lo que se le ha ordenado comprar. Ahora obviamente va a depender del tipo de contrato.

Importancia: La auto contratación es una herramienta muy importante en las sociedades. Es importante además porque la mercantilidad no esta dada por las partes. (Las cosas son lo que son y no lo que dicen que son).

Hasta acá hemos visto los ADC que pueden ser ejecutados por personas naturales, tal como lo señala el enunciado, son actos de comercio para una de las partes o para ambas. Es decir, puede ser un acto que contemple esta característica de ser mixto. Y si aun nos queda la duda lo determinados en virtud de la teoría de lo accesorio.

Hemos visto algo muy relevante que es que no están los inmuebles. Estos siguen fuera de la enumeración de los ADC.

ACTOS EJECUTADOS POR EMPRESAS

Muchos de los problemas jurídicos y conflictos que se someten al conocimiento y decisión de los tribunales, son por este tema. Y se resuelve también por el principio de que “las cosas son lo que son y no lo que dicen que son”.

Los actos ejecutados por empresas, están singularizados en los numerales 5 al 9 y en el numero 20 del artículo 3º del Ccom.

Toman en consideración mas alla del acto mismo, que estos sean ejecutados por las empresas. Acá el código no distingue que tipo de empresas, y no se queda pensando si tiene una determinada forma jurídica o no.

Existen muchos tipos de sociedades:

- a) Sociedad colectiva Civil
- b) Sociedad colectiva mercantil
- c) Empresa individual de responsabilidad limitada
- d) Las sociedades por acciones
- e) Las sociedades de responsabilidad limitada
- f) Las sociedades comandita
- g) Las sociedades en comandita por acciones

Pero acá el legislador no distingue, solo dice “las empresas”, pero ¿Qué es una empresa?, ya vimos lo que era un establecimiento de comercio.

El artículo 3º del CdT señala: “Para los efectos de la legislación laboral y de seguridad social, se entiende por empresa toda organización de medios personales, materiales e inmateriales, ordenados bajo la dirección de un empleador, para el logro de fines económicos, sociales, culturales o benéficos, dotada de una individualidad legal determinada.”

Esa es la definición que establece el artículo 3 del CdT que es un código que en su redacción es mucho menos compleja. Es un articulado que esta en permanente revisión. Pero la definición es muy completa. La empresa, es una organización de medios personales y materiales ordenados bajo una dirección para el logro y fines económicos.

Pero hay otras definiciones, en la ley 17.073 que crea el Rol Único Tributario en el Artículo 2 N°4: Por "empresa", **todo negocio, establecimiento u organización de propiedad de una o varias personas naturales o jurídicas**, cualquiera que sea el giro que desarrolle, ya sea éste comercial, industrial, agrícola, minero, de explotación de riqueza del mar u otra actividad.

Es decir, cada vez que estamos hablando de una empresa estamos hablando de una unidad económica de producción de bienes y servicios. Sea cual fuere la forma en que este constituida, bien como persona natural o jurídica, como S.A, Ltda, etc.

La ley opto por definir que son ADC, los siguientes:

- 1) Las empresas de fábricas, manufacturas, almacenes, tiendas, bazares, fondas, cafés y otros establecimientos semejantes.
- 2) Las empresas de transporte por tierra, ríos o canales navegables.
- 3) Las empresas de deposito de mercaderías, provisiones o suministros, las agencias de negocios y los martillos.
- 4) Las empresas de espectáculos públicos, sin perjuicio de las medidas de policía que corresponda tomar a la autoridad administrativa.
- 5) Las empresas de seguros terrestres a prima, incluidas aquellas que aseguran mercaderías transportadas por canales o ríos.
- 6) Las empresas de construcción de bienes inmuebles por adherencia, como edificios, caminos, puentes, canales, desagües, instalaciones industriales y de otros similares de la misma naturaleza”.

Siempre y cuando estén ejecutados por empresas.

Pregunta: ya sabemos que puede existir una figura con personalidad jurídica independiente constituida por una sola persona, pero ¿puede existir una empresa de una sola persona natural? Si, en la medida en que tenga esta organización dotada de la facultad para producir bienes y servicios y hacer la intermediación. ¿Me conviene ser persona natural o empresario? Da lo mismo, porque el régimen tributario no depende si soy o no empresa, sino que depende de que tipo de empresa soy. En general, todas las empresas tributan en primera categoría, los trabajadores dependientes tributan en segunda categoría.

¿Cuales son estas empresas?

- V. Las empresas de fábricas, manufacturas, almacenes, tiendas, bazares, fondas, cafés y otros establecimientos semejantes.

Acá nos encontramos con un concepto importante, para el profesor este numeral demuestra que la enumeración del artículo 3 es enunciativa. Es la prueba más clara.

Este numero dice “otros establecimientos semejantes”, ¿Cómo va a ser taxativa la enumeración si dice eso? El propio legislador lo dice y lo deja abierto.

Pero para toda la doctrina y jurisprudencia es taxativo. Asique mientras no haya una modificación legal se debe operar bajo la esfera de la taxatividad.

20 de agosto

Estábamos viendo estos ADC que están siendo ejecutados por empresas y esta es la diferencia sustancial con el resto de los ADC que habíamos visto inicialmente.

Aquí es el concepto de empresa aquel que esta motivando a estar frente un ADC.

El N°5 es uno de los antecedentes en virtud de los cuales se cree que la enumeración es meramente enunciativa y no taxativa.

Este numeral señala que son ADC “Las empresas de fábricas, manufacturas, almacenes, tiendas, bazares, fondas, cafés y otros establecimientos semejantes”.

a) Empresas de fabrica

Se refiere a todo aquello que es transformación de materias primas para un sector terciario que es en general el comercio al detalle o retail.

En 1875 cuando se dicto este Código, se refería al sector secundario.

El concepto determinante acá no es que tipo de fabrica es, da lo mismo. Acá el concepto determinante es que el ADC esta siendo ejecutado por una empresa, de suerte tal que cada vez que estemos frente a una empresa podemos entender que hay un ADC, porque no es una delimitación total la que establece el N°5.

b) Manufacturas

Son las obras hechas a mano o con el auxilio de una maquina.

c) Almacenes

Es distinto al N°7 que habla de las empresas de depósito de mercadería. Y aquí surge la duda, porque existe una ley de garantía que es la de almacenes generales de depósito o Warren. Son empresas de depósito que están asociados a tipo de puertos o aeropuertos, donde se dejan las cosas mientras se producen los trámites de desafectación aduaneras, etc. Tienen una relevancia tremenda para el comercio internacional.

Pero acá no estamos hablando de estos almacenes generales de depósito. Sino que hablamos de almacenes.

Doctrinariamente se ha dicho que estos almacenes, son las tiendas donde se venden artículos domésticos de primera necesidad.

¿Qué pasa entonces con los supermercados? Es mercantil, porque se cumplen los requisitos. Es una empresa con intermediación de bienes, con ánimo de lucro. Esto se prueba por la simple circunstancia de que si compro algo en un supermercado y venía fallado, puedo pedir la reposición e incluso me puedo amparar en las normas de la ley LPC, donde claramente hay proveedor de un BoS y un consumidor. El tema es, si se considera o no un almacén.

Por ejemplo, el caso de Almacenes París. Sabemos que el derecho comercial es evolutivo. Que sea evolutivo no implica en caso alguno que tengamos que dictar nuevas leyes para cada caso. Ahora, ¿París, vende producto de primera necesidad? Sí. Además es parte de un conglomerado que es Cencosud. Este gran conglomerado que en la actualidad se conoce como Holding, tiene en venta artículos de primera necesidad, por tanto podemos entender que estamos frente a unos almacenes.

La cuestión, es que tenemos que retroceder a 1875 y en ese año no existía el comercio de supermercados, porque ese concepto proviene de la post guerra de la segunda guerra mundial. Y de ahí surgió este concepto. Antes no exista.

En 1875 no existían estos grandes almacenes. Pero el análisis que debemos hacer es que la ley no distingue de grandes o pequeños almacenes, sino que habla de almacenes que son aquellos que venden artículos de primera necesidad.

Entonces, cuando hablamos de almacenes tenemos que incluir acá – sin necesidad de extendernos a una terminología abierta que da el numeral – a aquellos que venden al detalle, al por menor, sea cual fuere su forma jurídica, su tamaño, si cotiza en la bolsa o no, etc. En todos casos estaremos frente a un ADC.

La legislación mercantil peruana, establece respecto de los almacenes, que cualquier tipo de tienda de productos al por menor, o el retail.

Como sabemos se puede vender al por menor o al por mayor, al por menor cuando se compra por el consumidor final, al por mayor cuando se vende para que otro produzca.

En Chile no está esta distinción y desde 1875 hablamos de almacenes.

d) Tiendas

Pero no solo hablamos de barrotes, porque la propia ley agrega este concepto de tienda.

Ya no hablamos de artículos de primera necesidad, ¿de adonde viene este concepto de tienda?

El concepto de tienda está porque antes existían las ferias, y ahí habían puestos y esos puestos eran tiendas.

Aquí no solo se venden abarrotes, sino que se vende cualquier cosa al detalle, es decir, se le vende directamente al consumidor final.

e) Bazares

Bazar es una palabra que proviene del árabe. Estos también implican tienda, pero se refería antiguamente a donde vendían productos de primera necesidad y sobre todo telas.

Antes la gente se hacía su propia ropa. Se refiere a las sastrerías.

f) Empresas de café

¿Nos estamos refiriendo a la productora de café o al lugar donde se vende para el consumo final?
¿Qué pasa si no estoy constituido como empresa y vendo café?

La gracia del ADC que estamos estudiando es que está ejercido por una empresa, si yo no lo hago constituido como empresa estoy fuera de ADC. Tenemos que atender a “empresa”.

No se trata de la empresa productora de café, sino que se trata de la empresa que está sirviendo este café para el consumo inmediato.

¿Porque no está incluida la empresa productora de café? Esto es una actividad agrícola, y estas – así como los inmuebles – están fuera de los ADC. La agricultura no es un ADC. Como está desarrollando una labor extractiva agrícola está fuera de la enumeración del ADC.

En este caso cuando habla de las empresas de café, se refiere a lugares donde se vende el café para el consumo inmediato y no a las productoras de cafés.

g) Otros establecimientos semejantes

Lo relevante es que estamos viendo que todo aquel que se organice como empresa para la venta o intermediación de un servicio con ánimo de lucro en forma permanente, y que no sea extractivo, estará ejecutando un ADC.

Eso es absolutamente relevante para efectos de saber legislación aplicable, prescripción, prueba etc.

Por eso estos numerales son muy determinantes en cuanto a que establecen la obligatoriedad de que se trate de una empresa.

Por ende, no solo se debe atender al acto. Sino a que si hay o no una empresa detrás de eso.

VI. Las empresas de transporte por tierra, ríos o canales navegables.

Son empresas de transporte. El transporte por naturaleza es una actividad absolutamente civil. De suerte tal que será mercantil si es realizada por una empresa que se dedica habitualmente a esto con ánimo de lucro.

Pero el transporte es civil, es mas, siguiendo a los profesores Gonzalo Baeza y Gabriel Palma, que tienen un criterio empresarial, toda vez que el transporte sea realizado por una persona que no este constituida como empresa se mantendrán en una actividad civil.

Por ejemplo, si tengo un taxi y ejerzo este transporte sin estar constituido como empresa, estos profesores dicen que estaré ejecutando una actividad civil.

Para nosotros, lo relevante es que el transporte es una actividad civil regulada por la legislación y en la medida que sea ejecutado por una empresa, estamos frente a un ADC y lo vamos a tratar en cuanto a la legislación aplicable.

Para evitar problemas, en algunos fallos se establece que hay que atender a la naturaleza del acto, aunque estuviera constituido por una SA. Pero las legislaciones modernas quieren evitar este problema.

Por ejemplo, si soy taxista y tengo mi propio taxi, y me constituí como empresa individual de responsabilidad limitada, obviamente soy un empresario y estoy dentro de un ADC.

En la ley de empresas individuales de responsabilidad limitada, se establece que se entiende que todos los actos que hace el empresario son ADC. Por ende, se entiende que se mercantilizan.

Es decir, la ley opto actualmente por ratificar con un sentido positivo que todo aquel que tiene un acto que ejecuta a través de una empresa esta ejecutando un ADC, mas alla del acto en si.

Por ejemplo, el depósito es un acto civil, el transporte es un acto civil, pero si está constituido como empresa, estamos hablando de un acto necesariamente mercantil.

Ahora la ley habla de empresas de transporte por tierra, ríos o canales navegables.

Sobre esto hay 2 particularidades:

- a) **No se considera el transporte marítimo.** Porque en 1875 era tan relevante el transporte o el comercio marítimo que el propio legislador establece los ADC marítimos en una enumeración aparte, por su relevancia y significado.
- b) **En cuanto al transporte aéreo.** En 1875 no existían los aviones, no había comercio aéreo. Se ha interpretado que el transporte aéreo debe incluirse dentro de este concepto del N°6 por tratarse de una actividad económica que desarrolla una empresa. Se dice que si en 1875 se hubiese conocido el transporte aéreo es evidente que iba a quedar dentro del numeral. Aquí también tenemos que incluir el transporte aéreo.

VII. Las empresas de depósito de mercaderías, provisiones o suministros, las agencias de negocios y los martillos.

Este número no se entiende. Aquí mezclo todo el legislador. (Es como la norma de la acción pauliana civil).

¿Porque se mezclan estos tipos de empresas? Lo que pasa es que el Ccom, se aleja de definir lo que es un ADC y opta por nombrarlos, da la impresión de que esto fue incorporándose en las actas normativas.

El concepto determinante hubiera bastado con decir “empresas”.

- a) Empresas de depósito de mercadería

Acá otorga la mercantilidad de cada uno de estos actos, es la ejecución del acto por la empresa. Si depósito cualquier cosa, (no hablamos del depósito de la cuenta corriente que son siempre mercantiles).

El acto para la empresa de depósito será un acto mercantil, pero para quien lo deposita es civil. Aquí hablamos de actos que básicamente son mixtos o de doble carácter toda vez que son mercantiles para la empresa, pero civiles para la contraparte.

Lo relevante es que estamos frente al concepto del depósito, y el depósito de mercadería es una actividad civil. Pero lo que pasa es que si estos actos son ejecutados por una empresa estaremos frente a un ADC.

Aquí tenemos que tener la amplitud de distinguir que hay una empresa, la cual va determinar si estamos frente a un acto civil o mercantil.

b) provisiones o suministros

Acá estamos frente a un tipo de contrato totalmente distinto, que no guarda relación alguna con el depósito, toda vez que el suministro es un contrato por el cual una parte, que es el suministrador se compromete con otro, que es el suministrado, a realizar entregas o prestaciones periódicas en un periodo determinado o determinable.

Nosotros estamos expuestos mas a los suministros de servicios básicos. Que son tales como, el agua, gas, calefacción, internet.

Todos estos contratos por el cual una parte se compromete a realizar entregas o prestaciones periódicas a otras serán contratos de suministros. No es un contrato que se agote por la mera prestación, porque son contratos de tracto sucesivo.

Los contratos de tractos sucesivo son aquellos que se van cumpliendo y ejecutando en prestaciones permanentes durante un tiempo.

La diferencia de un contrato de tracto sucesivo, con un contrato de ejecución inmediata es que los contratos de tracto sucesivo por naturaleza son los arrendamientos. Pero la diferencia entre un contrato de tracto sucesivo y uno de ejecución inmediata es que el primero, no se pueden resolver, sino que se terminan. Por ello, uno no demanda la resolución del contrato, sino que demanda el termino del contrato.

Nunca se debe demandar la resolución del contrato de arrendamiento, sino que se debe demandar el termino.

Lo relevante es que el contrato de tracto sucesivo y el contrato de suministro, tiene por objeto permitir a la persona estar con todos los bienes que ha contratado.

Esto se relaciona con la figura de los contratos de adhesión.

El problema que tiene el contrato de suministro es que frente a nosotros como particulares, nos pueden cambiar las condiciones. Se puede vulnerar la relación de asimetría entre proveedor y consumidor.

c) Martilleros.

Son aquellos que hacen la adjudicación de los bienes en una publica subasta. Una publica subasta quiere decir que pueden participar todos los que quieran.

Por ejemplo. Si se subastan paquetes accionarios para obtener el control de un banco, ¿podríamos participar?

Una publica subasta no quiere decir que sea aquella que por su naturaleza todos podemos participar, sino que todos aquellos que cumplan las condiciones que se establecen para poder participar en la subasta.

Para participar de toda subasta se necesita rendir una caución de seriedad que normalmente equivale al 10% del mínimo. Y después de cumplir los requisitos podemos comprar o participar de esta publica subasta.

Ejemplo, ¿Qué pasa si soy un conocido delincuente y mis recursos económicos proviene del mercado de la droga? Y quiero comprar acciones del Banco de Chile, ¿puedo hacerlo? Si. Una empresa o accionistas no pueden oponerse a que se compren las acciones, porque si se afecta la libre cesión de las acciones hay problemas. No me puedo oponer a la libertad de mercado.

Empresas de martilleros comunes: Tattersal, Del rio, etc.

El problema que hay martilleros que se dedican a blanquear bienes, o sea, bienes que son de dudoso origen los terminan rematando y ahí se puede producir un nivel de problemas.

Para ser martilleros hay que estar inscritos en un registro que establece el ministerio de economía. Se deben cumplir ciertos requisitos y condiciones.

d) Agencias de negocios.

Termina el numeral 7 hablando de las agencias de negocios. Este concepto no esta claramente definido en la legislación.

Inicialmente las agencias de negocios se establecen para fomentar y establecer negocios.

Puede ser una comisión, un corretaje, aunque cada uno de ellos tiene su propio numeral.

Esto es algo que puede entender como una empresa de lobby, porque son los que hacen los contactos.

Jequier las define como “prestación de servicios de diversa naturaleza que realiza una persona en favor de varias otras en forma simultanea de manera profesional y estable”. No es solo 1 tipo de negocio, sino que a varias personas les ofrezco distintos negocios de distinta naturaleza.

La agencia de negocios cada vez pierde mayor presencia porque la especialidad la esta derivando a otro tipo de negocios.

- VIII. Las empresas de espectáculos públicos, sin perjuicio de las medidas de policía que corresponda tomar a la autoridad administrativa.

Aquí se abarcan todas las empresas para entretener al publico de cualquier artista. Aquí la mercantilidad esta dada por la empresa.

Si en cambio, el artista realiza el acto por si solo, seria un acto meramente civil.

Por ejemplo, un concierto. Para el cantante es una actividad mercantil si viene con una empresa constituida. Pero si viene solo, será civil.

Para la empresa que organiza, para ellos el concierto será mercantil.

¿Qué pasa con los que venden el show?, por ejemplo, para la empresa de punto ticket. Es una empresa que esta intermediando para un negocio en particular. Por ende seria una actividad mercantil porque esta dentro de su giro.

- IX. Las empresas de seguros terrestres a prima, incluidas aquellas que aseguran mercaderías transportadas por canales o ríos.

El seguro es un contrato originalmente civil, es asegurar y caucionar.

Acá hablamos de que con la evolución del tiempo hubo que asegurar ciertas mercaderías, y a esto se refiere el contrato de seguro.

Solo pueden ejercer el comercio de seguros en chile las SA abiertas, y por tanto estamos siempre frente a una actividad mercantil.

Lo mercantil, es que se ejerce por una empresa y por tanto siempre va a ser mercantil en este caso porque de conformidad a lo dispuesto en el DFL 251 solo las SA abiertas pueden ejercer como compañías de seguros. Obviamente mercantil para la empresa.

Si por ejemplo aseguro mi auto o mi casa, es una actividad civil. Pero para la empresa es siempre mercantil.

El numeral noveno se refiere a empresas de transporte terrestre y el comercio marítimo queda excluido porque está tratado en numerales siguientes. (del 13 al 19)

- X. Las empresas de construcción de bienes inmuebles por adherencia, como edificios, caminos, puentes, canales, desagües, instalaciones industriales y de otros similares de la misma naturaleza.

Ojo que este numeral no es el 10, es el numeral 20, pero se ve dentro de los ADC ejecutados por empresas.

Es el artículo 3 N°20, que son las empresas de construcción de inmuebles por adherencia. Aquí es primera vez que mencionamos a los inmuebles como parte de un ADC.

Ya sabíamos que estaban totalmente fuera de los ADC, acá se mencionan, pero no todos.

No abarca toda la actividad de los inmuebles, sino las empresas de construcción de bienes inmuebles por adherencia.

Los inmuebles por adherencia son aquellos que no se pueden retirar del inmueble al cual acceden porque están adheridos.

Hay otros inmuebles, que son los inmuebles por destinación, que son aquellos que se reputan que son bienes muebles por naturaleza, pero inmuebles por destinación, están destinados al uso, cultivo o beneficio de un predio determinado. por ejemplo, las herramientas para el cultivo. Todo eso está fuera.

Acá hablamos de empresas de construcción de inmuebles por adherencia, como edificios, caminos, puentes, canales, desagües, y otros de similar naturaleza. Nuevamente deja abierto el numeral.

Pero son empresas de construcción, es decir, la construcción es un contrato civil, y de hecho está regulado en el Código Civil como la confección de obra material. Sin embargo, esta actividad cuando es desarrollada por una empresa se torna mercantil.

Fue la necesidad de regular esta actividad lo que la transformó en un ADC. Por ende, se incluyen estas empresas de construcción.

Por ejemplo, si tengo una empresa constructora y voy a construir un edificio, ¿la venta del inmueble es civil o mercantil? Civil, porque el legislador solo estableció como actividad mercantil las empresas constructoras de inmuebles por adherencia y no la venta.

La venta inmobiliaria es una actividad civil. Solo los actos de construcción ejecutados por una empresa son ADC.

¿Qué pasa con el corretaje de propiedades? Si esta fuera de los ADC la venta, el corretaje también. Salvo que sea una comisión mercantil, que sería un mandato que es siempre mercantil.

Los corretajes son una actividad mercantil en la medida que estén constituidos como empresas. Pero si la venta de los inmuebles es netamente civil, el corretaje también. Quien puede lo mas puede lo menos. Pero esto es discutible.

Pero al tenor literal de la ley, lo que está establecido es que las empresas de construcción de inmuebles por adherencia son mercantiles y el resto son civiles.

ACTOS FORMALES DE COMERCIO

Son 3 tipos de actos y da lo mismo quien los ejecute, son siempre actos mercantiles. Da lo mismo si los ejecuta un agente civil o de comercio. Por ende se mercantiliza el concepto.

- XI. Las operaciones sobre letra de cambio, pagarés y cheques sobre documentos a la orden, cualesquiera que sean su causa y objeto y las personas que en ella intervengan, y las remesas de dinero de una plaza a otra hechas en virtud de un contrato de cambio. (Numeral 10º)

Da lo mismo el agente que los ejecute, sino que es el tipo de acto.

Las operaciones sobre letra de cambio, pagarés y cheques: acá tenemos el fundamento máximo del derecho comercial, que son las letras de cambio, pagares y cheques.

Se cambio radicalmente el concepto de utilizar monedas y empezar a usar documentos representativos de plata.

Por ejemplo, cuando un mercader tenía que trasladarse de alguna ciudad llevaba sus monedas y sacos de oro o plata para comprar mercadería y traerla pero en el camino le robaban. ¿Que hace el mercader? Nada. Entonces se les ocurrió que existieran documentos representativos de plata y que fueran pagados.

Entonces se crean documentos que eran letras de cambio que dicen “páguese a... en el banco X de esta ciudad” y si robaban el documento no robaban la plata. Eran documentos nominativos.

Después surgen los cheques, que eran ordenes de pagos. Ya no se usan mucho.

Y luego solo surgen los pagares, que es una orden de pago porque dice “Yo debo ... y pagare ... a la orden de ... la suma de” así de simple.

Cambiaron la modalidad cambio. Ahora usamos instrumentos de pago.

Por ejemplo, yo le presto 100 mil pesos a alguien, y le hago una transferencia. ¿vimos plata en efectivo? No. Sin embargo, nadie discute que efectivamente circularon los 100 mil pesos.

Por eso también son actos formales de comercio las remesas de dinero de una plaza a otra hechas en virtud de un contrato de cambio.

Todas las operaciones de cambios, pagares, cheques y remesas de dinero son actos formales de comercio sea quien fuere el que los ejecute.

31 agosto

De esto se destaca que las operaciones que se realicen son los actos mercantiles, pero no son mercantiles necesariamente las relaciones jurídicas subyacentes.

Por ejemplo, si yo vendo mi auto a alguien, ¿es operación civil o mercantil? La operación es civil. Si pago el auto con cheque, seria mercantil.

Cada vez que realizamos un acto con un cheque, letra de cambio o pagare, estamos frente a un ADC, pero las operaciones mercantiles son esas exclusivamente. La compraventa que se hace es civil. O sea, el acto o el contrato es civil, no se mercantiliza, pero el pago es mercantil. La operación en si misma es civil.

Lo que pasa es que es así porque siempre tradicionalmente se pagan en efectivo. Y para que el pago produzca el efecto de extinguir las obligaciones debe ser de contado, no se consideran los títulos de créditos.

Pero los títulos de créditos vienen a reemplazar la plata. Pero ahora nadie paga con plata. Y ese acto, en si mismo de pagar con una letra de cambio, cheque o pagare o hacer una remesa, va a ser un acto mercantil, pero eso no quiere decir que la compraventa vaya a mercantilizarse.

Esta distinción importa porque si se paga algo con un cheque que no tiene fondos, ¿Cómo se demanda?

Se puede hacer una gestión preparatoria de protesto de cheque y es más, porque el cheque es un titulo ejecutivo y podría cobrar un titulo ejecutivo, por una demanda ejecutiva.

Además, si yo no lo deposito o consigno dentro de 3er día notificado el valor del cheque en el tribunal, incluso de podría querellar por el giro doloso del cheque. Cuando tengamos que cobrar o ejercer una acción de cobro, se debe iniciar una demanda de cumplimiento forzado o de

resolución de contrato por indemnización de perjuicios, una gestión preparatoria de cobro de cheque e interpongo una querrela por giro doloso del cheque. Nunca nos debemos limitar a una sola acción. Es mas, si tenemos un titulo ejecutivo hasta podríamos pedir la liquidación concursal. Además, por estafa.

Y además jamás se debe aceptar el pago de una obligación por cheque. ¿Por qué?, el cheque no significa tener plata. Esa es la diferencia entre un cheque y un vale vista.

En cambio, el vale vista es plata que esta. Para tomar un vale vista tengo que tener la plata en el banco. Si voy al banco y pido un vale vista por mil millones de pesos, resulta que no me lo van a emitir, porque no tengo la plata.

Entonces la diferencia entre el vale vista y el cheque, es que yo puedo girar un cheque, pero no necesariamente estoy entregando plata, el cheque no significa que haya plata en la cuenta, en cambio el vale vista si. El cheque solo es una orden de pago.

El asunto es el siguiente: compre un auto y pague con un cheque, (se asume que tenemos fondos), esa operación de pago con el cheque es mercantil porque es un acto formal de comercio, pero no alcanza a mercantilizar la relación jurídica.

XII. Las operaciones de banco, las de cambio y corretaje.

Por eso hablábamos el tema del corredor. Aquí se refiere a las corredurías de dinero, que es algo que ya no se ve. Son siempre formales de comercio.

a) Operaciones de banco

Son operaciones de banco, la captación y colocación. La colocación es prestar plata, contratos de financiamiento, pagares, créditos de consumo, hipotecarios, leasing financiero, leasing operativo, etc.

La captación es todo lo que es captar plata, por ejemplo, depósitos, fondos mutuos, deposito a plazo, fondo UF, etc.

¿Como gana el banco? Por la diferencia que se produce entre la tasa de captación y colocación. Ese es el spread del banco.

Los bancos solamente pueden ejercer su comercio a través de SA abiertas, que son sociedades de capital. A diferencia de las sociedades de personas donde lo importante ahí es la calidad del socio porque hay una affectio societatis.

Lo relevante aquí es que las operaciones de banco siempre serán a través de SA, y un tipo especial de estas que son las SA abiertas.

Las operaciones de banco son siempre formales y siempre a través de SA. De suerte tal que cada vez que nos refiramos a una operación de banco estamos hablando de una operación mercantil.

XIII. Las operaciones de bolsa.

¿Por que la ley distingue las operaciones de bolsa? Porque las operaciones de bolsa es una actividad que regula el valor de transacción de los bienes y de las empresas.

La particularidad de las operaciones de bolsas es que ellas determinan la transacción y el valor de las empresas.

Aquí surgen los conceptos de IPSA o IGPA. Son dos tipos de indicadores de como se esta moviendo la bolsa.

- a) IPSA: Índice de precio selectivo de las acciones
- b) IGPA: Índice general del precio de las acciones

Estos indicadores existen para saber el valor de transacción, como se mueve la economía.

Por ejemplo, típico que se dice “cayo la bolsa” ¿Qué significa eso? Que en general el nivel de transacciones bajó, hubo una menor posibilidad de compra y por ende los precios bajaron. Y eso es lo que las empresas no quieren. La idea de comprar acciones es comprar barato para vender caro, ese es el negocio. Estos índices nos señalan el valor general de las acciones de todas las empresas que están cotizando en la bolsa o de algunas selectivas. Y según eso será influencia para el resto.

Transar en la bolsa es vender acciones. Es la compra y venta de acciones. Se hace una especulación económica.

Todos sabemos lo que paso en la crisis de 29, donde la especulación mato la economía.

También esta el caso de La Polar, esta era una empresa de retail grande y empezó a crecer y empezaron a adulterar los estados financieros, porque encontraron estados financieros en donde se decía que tenia un valor de transacción impresionante. La acción de la Polar llego a costar como 5.500 pesos. Pero después se dieron cuenta que los estados financieros estaban mal y en realidad la empresa costaba 400 pesos. Esto afecto la credibilidad financiera, paso a ser una Sociedad “AFPable”, es decir, aquellas en que las AFP podían invertir, y las AFP controlan la

plata de todos los chilenos. Entonces las AFP invirtieron en una empresa que resulto que no tenia nada, entonces perdimos todos. Por eso la importancia.

En nuestra realidad país, el 85% de las empresas de nuestro país no transan en bolsa. Sin embargo, esas empresas son las que determinan el valor bursátil.

Por ejemplo, las empresas de factoring, son empresas de financiamiento que están en una línea posterior al financiamiento que realizan los bancos. Los bancos si tiene que hacer operaciones de bolsa y si tienen valor de transacción. Pero el factoring no necesariamente, pero van a valer tanto o según pueda variar el negocio de los bancos.

Por eso la importancia de que todas las acciones y todas las operaciones de bolsa necesariamente tiene que ser mercantiles.

Además, que para ser corredor de bolsa se debe estar inscrito y también tenemos que ser una SA abierta.

Con esto terminamos los actos formales de comercio propiamente tales.

Después la ley se refiere a operaciones del comercio marítimo que no vamos a analizar, porque el principal comercio hasta el día de hoy es el mar, todas las operaciones comerciales que se efectúan por el mar son actos de comercio, incluyendo el seguro, la carga, los almacenes, etc. No existe una operación referida al mar que sea civil.

Son los siguientes:

- 1°. Las empresas de construcción, carena, compra y venta de naves, sus aparejos y vituallas.
- 2°. Las asociaciones de armadores.
- 3°. Las expediciones, transportes, depósitos o consignaciones marítimas.
- 4°. Los fletamentos, seguros y demás contratos concernientes al comercio marítimo.
- 5°. Los hechos que producen obligaciones en los casos de averías, naufragios y salvamentos.
- 6°. Las convenciones relativas a los salarios del sobrecargo, capitán, oficiales y tripulación.
- 7°. Los contratos de corredores marítimos, pilotos lemanes y gente de mar para el servicio de las naves.

El estudio de todo lo que hemos visto hasta acá es para entender la importancia del derecho comercial y cual será la legislación aplicable.

ADC FUERA DEL ARTÍCULO 3º DEL CCOM

Ya revisamos la enumeración de los ADC que establece el legislador. Sin embargo, a pesar de la tesis objetiva de los ADC la doctrina sostiene que igual existen otros ADC fuera del artículo 3º del Ccom.

Estos ADC tienen reconocimiento jurisprudencial.

I. Sociedades mercantiles

El artículo 2059 del Código Civil, señala que la sociedad puede ser civil o comercial, y son sociedades comerciales las que se forman para negocios que la ley califica como ADC.

El artículo 2064 Código Civil, dice que la SA es siempre mercantil aun cuando se forme para la realización de negocios de naturaleza civil. Ese artículo está repetido en el inc. 2º del artículo 1 de la ley de SA.

La jurisprudencia dice que la mercantilidad no está dada por el hecho de ser una SA, no está dada por lo que establezcan las partes, sino por la ejecución de ADC, de suerte tal que una SA que está constituida como tal que debiera ser siempre mercantil, no necesariamente será regulada por la ley mercantil si no está ejecutando ADC. Ver el fallo de las patentes.

No obstante, sea una SA, hay que atender a la naturaleza del acto y no a la sociedad misma.

Por lo mismo si en un contrato me identifico como un empresario, no necesariamente me rige la ley mercantil. La calidad de ADC no depende de lo que digan las partes, depende si están o no ejecutando un ADC.

II. Cuenta corriente mercantil

No estamos hablando acá de la cuenta corriente bancaria, porque ya sabemos que todas las operaciones de banco son ADC.

Acá hablamos de una cuenta corriente mercantil, y es muy simple.

Por ejemplo, tengo una empresa de pan y todas las semanas voy a comprar harina para hacer mi negocio del pan. Pero, podría ser muy complicado que vaya 2 veces a la semana a la empresa de harina y le compro y me emite factura y hago un pago, etc. Resulta que sería muy poco práctico.

Es mejor si voy 1 vez al mes, liquido la operación, le pago y se factura. Esa es la cuenta corriente mercantil.

Es la posibilidad de que uno u otro vaya pidiendo determinadas platas y que una vez cerrada la cuenta corriente se va liquidando y ahí se determina cuales son los saldos a favor y en contra. Lo habitual en el comercio es eso.

Nosotros estamos acostumbrados al comercio detallista. Pero a nivel de empresas, esto funciona a través de las cuentas corrientes, que se paga una vez al mes.

Esta regulada en los artículos 602 y ss. del Ccom, y es un ADC.

Art. 602. La cuenta corriente es un contrato bilateral y conmutativo por el cual una de las partes remite a otra o recibe de ella en propiedad cantidades de dinero u otros valores, sin aplicación a un empleo determinado ni obligación de tener a la orden una cantidad o un valor equivalente, pero a cargo de acreditar al remitente por sus remesas, liquidarlas en las épocas convenidas, compensarlas de una sola vez hasta concurrencia del débito y crédito y pagar el saldo.

III. Mutuos, prendas y fianzas mercantiles

Que son para garantizar obligaciones mercantiles. No están establecidas en ninguna enumeración del artículo 3º.

Por ejemplo, compro un establecimiento de comercio y para garantizar el pago del precio voy a dar una prenda o constituir una hipoteca. Esa prenda/hipoteca es mercantil. Además, la compra del establecimiento de comercio es siempre mercantil.

Las cauciones son obligaciones accesorias, porque caucionan una obligación principal. Y lo accesorio sigue la suerte de lo principal, y por ende si es una hipoteca que cauciona la compra de un establecimiento de comercio en virtud de la teoría de lo accesorio, pasaría a ser una prenda/hipoteca mercantil. Para liberar la prenda debo pagar la obligación.

La prenda y la hipoteca como tales van a ser civiles o mercantiles según si caucionan obligaciones civiles o mercantiles.

TAXATIVIDAD DE LOS ADC

¿Los ADC son taxativos o enunciativos? Aquí hay dos posturas.

I. Postura de la enunciatividad

1. Argumento gramatical. En primer termino, los ADC son enunciativos por un argumento gramatical. El artículo 3 del Ccom, parte diciendo "son ADC".

Si el legislador hubiera querido hacer una enumeración taxativa, hubiera partido diciendo "los actos de comercio son", pero cuando dice "son ADC" deja el tema abierto porque no esta excluyendo.

Si uno toma todo el Código Civil o el Ccom, cada vez que el legislador ha redactado una ley de manera taxativa define como "X son".

2. Como hemos visto, la enumeración del artículo 3 no contiene todos los ADC, no contiene:
 - a) Factoring
 - b) Cuenta corriente mercantil
 - c) Prenda e hipoteca mercantil
 - d) Empresas de franquicias
 - e) Contratos de financiamiento
 - f) Fusiones o adquisiciones de empresas

Mas encima vimos que el numeral 5º dice que son ADC las empresas .. "y otros establecimientos semejantes". Deja abierta la posibilidad de otro establecimiento semejante.

El numero 20º termina el numeral diciendo "y de otros similares de la misma naturaleza".

Por eso no puede ser taxativa, porque el propio legislador deja abierta la posibilidad.

La importancia de esta distinción es que nos hará ganar o perder un juicio. (Por la prescripción y la prueba, por ejemplo).

II. Postura de la taxatividad

1. Argumento gramatical: el Ccom es una ley excepcional cuyo ámbito de aplicación se refiere a los actos que están fuera de la legislación común, lo que se desprende del artículo 2º del Ccom, cuando dice la palabra "especialmente".

Art. 2º. En los casos que no estén especialmente resueltos por este Código, se aplicarán las disposiciones del Código Civil.

Por tanto, todo esta regulado en el artículo 3º, y si en este artículo 3º no aparecen los ADC, no lo son.

2. Argumento histórico: el actual artículo 3º en el proyecto del Ccom, era el antiguo artículo 7º y ahí se enumeraban los ADC igual que ahora. Pero luego el artículo 10º de este proyecto señalaba los que no eran ADC.

Y por su parte el artículo 11º del proyecto del Ccom decía *“los arts. 7 y 10 son meramente declarativos y no limitativos y en consecuencia los tribunales de comercio resolverán los casos por analogía.”*

El propio artículo 11º establecía que esta enumeración era declarativa. Pero eso se eliminó, de suerte tal que al haberse eliminado el artículo 11 refleja la voluntad inequívoca del legislador en orden a hacer taxativa esta enumeración.

3. El legislador optó por una enumeración ante la imposibilidad de definir el ADC de manera restrictiva. Como no se puede definir lo que es el ADC, se enumeran.
4. Finalmente, en el propio mensaje del Ccom, dice *“el Ccom ha huido del peligro de definiciones puramente teóricas y en vez de definir los ADC los ha descrito prácticamente enumerándolos”*. Entonces para evitar estas definiciones el Ccom opta por describir estos actos enumerando.

Toda la jurisprudencia señala que es taxativo. Entonces, tenemos este evento, tenemos esta discusión. Para Ocampo es enunciativa.

3 de septiembre

EL EMPRESARIO

Veremos quien es el comerciante. Desde una visión histórica, siempre se ha hecho la distinción entre el comerciante individual – que no es lo mismo que la EIRL – y el empresario de comercio.

Básicamente estamos hablando de lo mismo, de una persona que se dedica a ejecutar estos ADC. Bien sea que lo haga como persona natural o que lo haga constituido como empresa.

Este empresario puede ser una persona natural y tiene una serie de obligaciones que son las mismas que le corresponden a todo empresario, de suerte tal que aquí se hace énfasis a que la distinción entre empresario individual y empresario corporativo, no tiene mayor relevancia, porque las obligaciones son las mismas.

Obviamente, a un empresario corporativo, se le imponen otra serie de obligaciones que no tiene el empresario individual, que son aquellas que emanan de la naturaleza jurídica de la empresa que tiene organizada. Y sobre todo, si hablamos de empresas que tienen intereses de terceros como son las S.A., las SpA, que son empresas en donde están muy “atomizadas”, es decir, donde el porcentaje de acciones le pertenecen a muchas personas, son mayores las obligaciones.

La persona que ejerce una empresa, la ejerza a título personal o a través de una figura jurídica distinta, tiene deberes que son deberes propios y deberes fiduciarios frente a los terceros, a los acciones o socios.

En el criterio del profesor, al concepto jurídico de empresario no es necesario hacerle una distinción entre una figura individual o societaria.

Sin embargo históricamente si se hacia esta distinción, y es porque en 1865 normalmente todos los comercios se ejercían a nivel individual, no existía mucho el desarrollo de las personas jurídicas. El movimiento de las personas jurídicas fue surgiendo en la medida en que se tenían que separar patrimonios, esto porque ningún empresario quiere que sus bienes personales se vean afectados por el ejercicio de una profesión, y por eso surge esta idea de separación de patrimonios.

Pero en 1865 lo normal era que uno ejerciera el comercio por si mismo, de hecho, hoy en día si pensamos en tener algún tipo de empresa, lo mas seguro es que se forme una sociedad. Antiguamente el concepto era “voy a tener un negocio”, y ese negocio esta regulado a través de la empresa individual. Pero son básicamente las mismas obligaciones que se ponen a través de empresa.

En una noción economicista, en una perspectiva de la simple teoría económica, el concepto de empresario se identifica directamente con la persona que coordina y ejecuta los distintos factores

de producción, es decir, un empresario es esta persona que ejecuta por si misma los factores de producción.

Sin embargo, para nosotros, el empresario, (sea cual fuere) no requiere desplegar esta actividad comercial en forma directa y personal, sino que puede hacerlo a través de terceros.

Esto, se regula de la siguiente forma en el CdC:

Titulo I De la calificación de los comerciantes y del registro del comercio - § 1. De la calificación de los comerciantes.

Art. 7º Son comerciantes los que, teniendo capacidad para contratar, hacen del comercio su profesión habitual.

Elementos de la definición

A. Capacidad

La regla del 1446 del Código Civil, toda persona es legalmente capaz, excepto aquellos que la ley declara incapaces. Es decir, todos son capaces, salvo aquellos que la ley declara que no.

Los incapaces pueden ser absolutos o relativos.

a) Absolutos

Los absolutamente incapaces son los dementes, los impúberes y los sordomudos que no pueden darse a entender claramente.

1º. Dementes

En cuanto a los dementes, ¿Qué pasa con el síndrome de Down?. Ellos son absolutamente incapaces. Cuando la ley habla de demencia, se refiere a cualquier estado de enajenación que prive de la razón. No solo de los dementes, porque la locura o demencia es una especie de privación de la razón. Acá hablamos de cualquier tipo de enajenación mental. Se incluye cualquier persona privada de razón.

2º. Impúberes

En cuanto a los impúberes, estos no son capaces y no pueden celebrar ningún tipo de contrato. Son los hombres que no han cumplido 14 y las mujeres que no han cumplido 12.

3º. Sordomudo

Son aquellos que no pueden darse a entender claramente. Los que no pueden darse a entender obviamente son incapaces.

b) Relativos

Los incapaces relativos, son los menores adultos y los interdictos.

1º. Menores adultos

Son los menores de 18 años. Hombres entre 14 y 18 y mujeres entre 12 y 18. Pueden celebrar determinados actos, pero en algunos casos van a tener que actuar o representados o bien tendrán que ser ratificados.

Ellos tienen una capacidad limitada para ejecutar ciertos actos y contratos. Pero en materia comercial, si ellos tienen bienes, si pueden ejecutar actos o contratos. Y tienen capacidad para administrar su propio peculio.

2º. Interdictos por disipación

Se trata de un despilfarrador. Esto también se relaciona con la figura del pater familias. Esta persona es incapaz.

¿Qué pasa con la mujer casada en sociedad conyugal? Antiguamente, era relativamente incapaz. Ahora esta derogada.

7 de septiembre

B. Profesión habitual

Que hagan del comercio su profesión habitual, significa que ejecutan actos de comercio. ¿Qué es la habitualidad? ¿Cómo se califica la habitualidad? ¿debe ser una o muchas veces? De partida, el que resuelve la habitualidad es el juez civil.

Para el SII es suficiente una sola vez para generar la habitualidad.

Habitualidad en sí misma es una reiteración de hechos, una ejecución reiterada de actos de comercio para entender que se es comerciante, pero esta es la regla general, porque puede ser que la ejecución de un solo acto de comercio sea suficiente para ser considerado comerciante, ejemplo, la compra de un establecimiento de comercio, porque éste compra generalmente para la explotación de su giro, aunque en la práctica no se lleve a cabo.

Además, para entender que estamos frente a un comerciante se requiere de un elemento subjetivo, que es el **ánimo**, la intención de ser comerciante. Así lo establece el artículo 8.

Art. 8º No es comerciante el que ejecuta accidentalmente un acto de comercio; pero queda sujeto a las leyes de comercio en cuanto a los efectos del acto.

Cuando se refiere accidentalmente no es que sea por descuido sino, que escapa a la habitualidad. Por tanto, el artículo 8º es una prueba de que existe un ánimo, la intención de ser comerciante. El ánimo de intermediar bienes o servicios con ánimo de lucro.

Esta calidad de comerciante se extiende hasta que cesa el ánimo, o con la muerte, la calidad de comerciante no se hereda, lo que se hereda son los efectos del comercio, calidad jurídica, efectos patrimoniales, cuentas, pero no la calidad de tal.

En el caso de las personas jurídicas, se terminan cuando se disuelven, que en todo caso no extingue la responsabilidad frente a los actos contratados, no se puede contraer obligaciones, disolver la sociedad y quedar sin obligaciones, estas se mantienen vigentes aun cuando la persona jurídica no exista. ¿Qué pasa si se solicita la liquidación concursal de una empresa? No sigue siendo comerciante.

La calidad de comerciante se debe distinguir si se está en presencia de una persona jurídica o natural.

La banca y todos los órganos de financiamiento utilizan la figura de seguro de desgravamen, donde sí se muere la persona es el seguro el que cubre. En los créditos del retail, se cobra en las cuentas el seguro de desgravamen sin que la persona lo contrate ¿es una cláusula abusiva? Sí, porque nadie informa, al momento de firmar la aceptación de la tarjeta se emite un mandato mercantil irrevocable para la empresa el que incluye la posibilidad de contratar un seguro.

La Corte en el caso de los seguros ha señalado que no es abusivo el seguro, lo que sí es abusivo es que no se informe de la existencia y de los cobros de los mismos.

La intención positiva incluye la intención de subsumirse en la legislación.

DELEGACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTOS O CONTRATOS

El comisionista está interesado en el contrato y por ende los efectos se radican en él. Ahora que los resultados del acto o contrato que se ha celebrado queden radicados en el patrimonio del mandante o comitente es distinto.

Pero siempre hay un interés personal en la ejecución de un acto de comercio que se efectuó a nombre propio.

¿Puedo delegar la ejecución de un acto o contrato mercantil en un tercero? ¿El comerciante puede delegarle a un tercero que lo represente en la celebración de un acto o contrato?

Si se puede. Porque se comprende que el dueño de un banco no ira a firmar los papeles de un banco, ni pagar sueldos. Todo lo hacen los gerentes generales que son mandatarios.

Todos los ADC se pueden delegar, lo relevante es que todos los actos o contratos mercantiles son delegables, con ciertas características y autorizaciones. Lo relevante es que los efectos del acto o contrato mercantil radiquen en el patrimonio del mandante o comitente.

Por eso se trata de una actuación a nombre propio del mandante o del comerciante, o del comitente.

Existe en Chile el “compra para”, por ejemplo yo compro para un tercero.

Siempre estaremos ante un comerciante cuando los efectos finales del acto se ejecutan a nombre propio. Radican en el patrimonio del propio comerciante. Por eso es que el artículo 8 señala:

Art. 8º No es comerciante el que ejecuta accidentalmente un acto de comercio; pero queda sujeto a las leyes de comercio en cuanto a los efectos del acto.

Este principio es general. No es comerciante el que accidentalmente ejecuta un ADC, porque no es una persona que haga del comercio su profesión habitual, pero queda sujeto a las leyes comerciales en cuanto a los efectos del acto.

La importancia de esta determinación, de esta definición de ser comerciante que establece la ley. Es para efectos de la capacidad, prueba, y obligaciones propias de los comerciantes.

EFFECTOS DE LA CALIDAD DE COMERCIANTE

Debemos distinguir los efectos de los actos de los comerciantes, y así como sabemos los efectos que se ejecutan durante el comercio, primero que todo debemos determinar hasta cuando se extienden los efectos del comercio o como se termina la profesión o calidad de comerciante.

Como se termina la calidad de comerciante en una persona natural:

1º. Con la muerte

Si me muero, la calidad de comerciante no se hereda.

2º. Termina de giro

Me retiro de la actividad mercantil, antiguamente en el SII se hablaba de giro o actividad. Corresponde a las actividades económicas que ejecuta la persona comerciante.

La persona natural será comerciante hasta que muera o se retira de la actividad mercantil.

Para el caso de las personas jurídicas, el efecto por el cual estas “mueren” es por la disolución. La persona jurídica, se extingue por la disolución. Hay causales propias.

Esta disolución puede ser voluntaria o por cumplimiento de la ley. Por ejemplo, la liquidación concursal de una sociedad implica su disolución. Y también puede terminar necesariamente por el término de giro.

En todo caso, la disolución de la sociedad no puede afectar los derechos de terceros, de suerte tal que se mantendrá la personalidad jurídica para todos los efectos de la disolución y liquidación.

Todos los efectos de la calidad de comerciante van desde que me instituyo en tal calidad, y termina cuando se acaba ese giro, o cuando se produce la muerte o disolución de una sociedad.

NORMAS PARTICULARES SOBRE LA CAPACIDAD

Las normas generales las sabemos, son todos capaces.

¿Qué pasa con las normas propias de la capacidad en materia mercantil?

Son 4 las normas que demuestran el espíritu de la legislación mercantil avanzado y moderno, por sobre el espíritu de la legislación civil.

1. Menores de edad

Art. 10. Cuando los hijos de familia y los menores que administran su peculio profesional en virtud de la autorización que les confieren los artículos 246 y 439 del Código Civil ejecutaren algún acto de comercio, quedarán obligados hasta concurrencia de su peculio y sometidos a las leyes de comercio.

La ley habla de los hijos de familia y los menores que administran. Hace una distinción que ya no tiene sentido en materia civil.

Pero acá nos referimos exclusivamente a los menores adultos, este menor entre 12 y 14 años y los 18 años, y la ley establece que es plenamente capaz para ejercer el comercio respecto de los bienes que son de su peculio.

Van a conjugarse dos normas, porque si un menor adulto quiere vender un bien raíz debe actuar representado por un adulto o el juez en subsidio. Si se trata de un bien mueble no se requiere esa autorización.

Y si esta dentro del peculio profesional, puedo hacerlo perfectamente. Ahora bien, aquí hay una duda, porque la ley dice que pueden actuar y que quedan obligados hasta la concurrencia de los bienes de su peculio.

En principio no hay problemas en celebrar actos o contratos con menores de edad respecto de su peculio, pero hay dudas porque no se sabe hasta donde van a responder.

La responsabilidad patrimonial de ese acto o contrato solamente va a quedar limitado en los bienes que forman el peculio profesional del menor.

Por su parte el artículo 18, señala: Art. 18. *El menor comerciante puede comparecer en juicio por sí solo en todas las cuestiones relativas a su comercio.*

Esta interpretación de lo que establece el artículo 18 si bien esta supeditada a un tema de comparecencia en juicio, nos conduce a pensar que el menor adulto si puede ser comerciante, porque puede ejercer el comercio y radica todos los efectos en su patrimonio e incluso puede comparecer en juicio por si solo.

Pero dice “comparecer en juicio por si solo”, esto se puede en los juzgados de policía local, en donde en general se ven accidentes de tránsito, ruidos molestos, problemas domésticos, o LPC. En estos asuntos se puede comparecer sin abogado, lo cual es una excepción a la ley de comparecencia en juicio.

Sin embargo, la ley dice que hay ciertos procedimientos que se puede comparecer sin abogado, y uno de ellos son los procedimientos que establece la LPC para acciones de naturaleza personal, y en ese caso el menor adulto si puede comparecer por si mismo en un juicio.

Pero, además, la duda es ¿puede un menor adulto comerciante conferirle a un abogado patrocinio y poder? Si puede en la medida que pague con su peculio.

El menor adulto puede comparecer en juicio, es decir, puede ser parte, puede ser sujeto activo o pasivo en un juicio. Y también puede otorgar los poderes respectivos, pero en la medida que actúe dentro de su peculio. Además, podría comparecer en los juzgados de instancias.

Si puede ejecutar el comercio, puede ejecutar todos los actos que deriven del comercio.

2. Mujer casada en sociedad conyugal

Art. 11. La mujer casada comerciante se registrará por lo dispuesto en el artículo 150 del Código Civil.

Hace esta distinción de la mujer casada comerciante, si la mujer no fuere casada obviamente puede ejercer todas sus actividades, entonces al parecer el hecho de que la mujer se case le impone una limitación al comercio.

Lo que dice es que la mujer casada en sociedad conyugal podrá ser comerciante conforme al artículo 155 y ss del Código Civil, es decir, a través de su patrimonio reservado. Todo lo que la mujer ejecute en el ejercicio de su profesión u oficio y todo lo que ella tenga a través de su profesión u oficio, se entiende separada de bienes. No tiene que pedir permiso.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 155 Código Civil, la mujer casada en sociedad conyugal de cualquier edad, podría dedicarse al comercio libremente y se le considerara separada de bienes, a menos que el juez se lo prohíba a petición del marido.

Por su parte el artículo 16 señala; *Art. 16. La mujer divorciada y la separada de bienes pueden comerciar, previo al registro y publicación de la sentencia de divorcio y separación o de las capitulaciones matrimoniales, en su caso, y sujetándose, además, si fueren menores de dieciocho años, a las reglas concernientes a los menores bajo guarda.*

Da a entender que la mujer divorciada si puede comerciar, pero la casada no. Esto no tiene sentido. Son normas muy antiguas.

Lo importante es que actualmente sea cual fuere el estado civil de la persona, se puede ejecutar el comercio, y las únicas limitaciones están siendo básicamente que lo ejecuten a través de un ejercicio propio y que radique en los efectos propios, no en los efectos de un tercero.

Aquí nos encontramos con lo que la ley establece que son prohibiciones y limitaciones para comerciantes.

Lo importante respecto al tema de los comerciantes y al tema de la capacidad, es que si contrato con alguien que esta casada en sociedad conyugal, voy a insertar en la escritura del contrato todos los documentos necesarios para acreditar que esta actuando bajo su patrimonio reservado. Esto para evitarme el juicio posterior.

21 de septiembre

Ya sabemos que el concepto de comerciante. Hay normas mucho mas flexibles en materia mercantil. El comerciante es aquel que teniendo capacidad hace del comercio su profesión habitual.

Y esas son las características propias de este comerciante. Además, la ley establece ciertas prohibiciones o limitaciones para comerciantes y nos encontramos con el artículo 19 CdC.

Art. 19. Los contratos celebrados por personas a quienes esté prohibido por las leyes el ejercicio del comercio, no producen acción contra el contratante capaz; pero confieren a éste derecho para demandar a su elección la nulidad o cumplimiento de ellos, a menos que se pruebe que ha procedido de mala fe.

Pareciera que existen ciertas prohibiciones para ejercer el comercio, pero en verdad son limitaciones o reglamentos o requisitos para ejercer el comercio.

El principio general de esto está en la CPR que es el artículo 19 N°21, que es la libertad de poder desarrollar cualquier tipo de actividad económica, salvo que sea contraria a la ley, la moral, las buenas costumbres, y el orden público. Esta es la protección como garantía que se le establece al comerciante.

Sin embargo, existen los comercios reservados, que son aquellos por los cuales el estado se reserva para sí determinados actos de comercio, por ejemplo, el transporte ferroviario, correos, etc.

Bajo nuestro sistema constitucional, existe lo que se denomina “el principio de subsidiariedad”, que está consagrada también en la CPR en el artículo 1 en el párrafo tercero cuando se reconoce la existencia de los grupos intermedios. En virtud de este principio de subsidiariedad se establece que hay ciertos tipos de actos o comercios que están reservados para el estado y otros en la medida que los particulares no puedan hacerlo de modo eficiente.

Entonces existen estos comercios reservados para el estado que pueden variar completamente. Existen también determinados comercios que están limitados en cuanto a la capacidad del comerciante para poder ejercerlos.

COMERCIOS LIMITADOS PARA DETERMINADAS ENTIDADES

No están prohibidos, sino que están absolutamente regulados para ser ejercido por este comerciante, estos son:

1. Actividad bancaria

Cualquier persona podría tener un banco cumpliendo los requisitos. El principal requisito es ser una SA abierta, que están reguladas por la CMF.

Además, se debe tener un capital pagado y reserva que sea amplio para poder garantizar un mínimo a los accionistas.

2. Comercio de seguros

Las compañías de seguro solo pueden ser también SA abiertas. Porque manejan muchos volúmenes de muchas personas.

3. Martilleros

La actividad del martillero esta reservada a todos los martilleros nombrados por un decreto presidencial y que están inscritos en las nominas del ministerio de economía. Es decir, no cualquiera puede ser martillero.

4. Farmacias

Es un negocio reservado toda vez que todos los farmacéuticos y sociedad en que figuren como socio un farmacéutico podrá adquirir o instalar farmacias. Esta farmacia debe ser establecida y constituida a través de un farmacéutico o a través de una sociedad en que un farmacéutico figure como socio de esta empresa. Esto porque las farmacias expenden remedios y hay responsabilidad detrás.

5. Colocación en publico de acciones, bonos y toda otra clase de títulos de valores de inversiones

Están solamente reservados para las empresas y sociedades operadoras de bolsa de comercio. Son las únicas que pueden realizar esta colocación publica de acciones, bonos y títulos de valores.

6. Las corredoras de bolsa

También deben estar inscritas. Son SA. Se les exige mucho estándar porque estos negocios se basan en la fe publica, en la buena fe. Y manejan plata que no es propia.

Esto emana de un principio general de que no solo obliga lo que esta pactado, sino que también todo lo que emana de su naturaleza y se deben cumplir de buena fe. Con mayor razón estas empresas que administran patrimonios ajenos tienen que responder de buena fe e incluso algunas de ellas con estándares mas altos en cuanto a los grados de culpa.

La culpa promedio en general es la culpa leve, pero acá cuando administra patrimonios ajenos, incluso puede llegar a responder de culpa levísima, como seria el caso de los procedimientos de liquidación concursal.

Finalmente, en cuando a estas limitaciones, no es que el artículo 19 cuando habla de los contratos celebrados por personas a quienes esté prohibido por las leyes el ejercicio del comercio, no

producen acción contra el contratante capaz, no se refiere a un comercio prohibido. No es que la ley este estableciendo prohibiciones, sino que simplemente regulaciones para ejercer el comercio.

Ahora bien, este artículo dice que en el caso de estos contratos celebrados por personas a quienes se les tiene prohibido, no producen acciones contra el contratante capaz, pero confieren *a éste derecho para demandar a su elección la nulidad o cumplimiento de ellos, a menos que se pruebe que ha procedido de mala fe.*

Si celebramos un contrato con una persona que no tenía capacidad, no se genera acción contra el contratante capaz, obviamente si yo era incapaz y celebro un contrato con alguien y esa persona era capaz. Por eso no se genera acción contra la persona capaz. Sino que la acción se le genera al contratante capaz quien va a poder hacer 2 cosas: pedir la nulidad del contrato por absoluta incapacidad o el cumplimiento forzado. A menos que se pruebe que ha procedido de mala fe. Es un principio general, nadie puede aprovecharse de su propio dolo.

Se puede pedir la nulidad de este contrato, pareciera que seria nulidad relativa, ¿pero como podría pedir la nulidad del contrato si quien la pide formo parte del contrato?

Si lo analizamos desde la perspectiva del derecho civil, si es nulidad absoluta ¿Cómo puedo pedir el cumplimiento? Porque se supone que la ley me otorga dos posibilidades, la nulidad o cumplimiento. Si fuera nulidad absoluta, ¿Cómo podría pedirse el cumplimiento? Si la nulidad se basa en que no existe. Es decir, ¿Cómo podría pedir el cumplimiento de algo que no existe? Las opciones que da la ley son excluyentes.

Entonces, pareciera ser que fuera nulidad relativa, pero la nulidad relativa no la pueden pedir las partes que concurren a la celebración del acto o contrato. Y es mas, le agrega una connotación especial, porque dice “a menos que se pruebe que ha procedido de mala fe”.

¿Cómo se prueba la mala fe?, se supone que es si sabia que el otro era incapaz. Pero puedo perfectamente desconocer las normas especiales de capacidad por ejemplo para una farmacia.

La norma es poco feliz. Si uno celebra un contrato con alguien y que esta prohibido por ley o que es un comercio reservado, da la impresión prima facie, de que es nulidad absoluta.

Los contratos que la ley prohíbe no se pueden invalidar, no producen efecto. Pero después dice que se puede pedir el cumplimiento, por ende, si se puede pedir el cumplimiento no podría ser nulidad absoluta. Porque no se puede pedir el cumplimiento de lo que no existe.

Y además agrega la mala fe. Pareciera que la mala fe existe en la medida en que no sepa y haya debido saber cuales eran los requisitos y aun así actuó.

Esto nos lleva a la presunción de la fe, hay una presunción de mala fe en materia de posesión en el Código Civil, se dice que habiendo un error de derecho, es de mala fe. Pero esto está dispuesto para materia de posesión.

Otra presunción está en el CPC, en las medidas prejudiciales precautorias, la ley establece que la demanda se debe interponer dentro del plazo del 5to día o el plazo que el tribunal haya fijado al efecto. Sino se entenderá de mala fe el procedimiento y deberá responder de los perjuicios.

Son casos muy aislados, porque la buena fe se presume. Probar la mala fe es complicado, porque esta requiere no solo la inobservancia de las normas, o incurrir en un error de derecho, sino que requiere esta intención positiva de causar un perjuicio a la personas, propiedad o bienes del otro.

Tenemos el problema de la prueba de la mala fe. Lo que el legislador con esta norma quiso decir es que si contratamos con alguien incapaz y no sabíamos ni podíamos saber, en ese caso podemos o pedir la nulidad del contrato o perseverar en el mismo y que se cumpla el contrato. El legislador mercantil, en el fondo, quiere que los contratos se cumplan y no que se anulen. Pero la norma del artículo 19 está mal redactada porque se contrapone con ciertos requisitos generales de Código Civil.

OBLIGACIONES DE LOS COMERCIANTES

El artículo 30 del CdC hace una distinción entre el comerciante al por mayor y al por menor.

El comerciante al por menor es aquel que vende directa y habitualmente al consumidor. Al por mayor, todo el resto. Aquí no se habla de volúmenes de empresas, sino de cómo se ejerce la venta, es una relación entre el vendedor y el comprador. No estamos hablando de si es una sociedad, una persona jurídica, etc.

Art. 30. Los comerciantes por menor llevarán un libro encuadernado, forrado y foliado, y en él asentarán diariamente las compras y ventas que hagan tanto al fiado como al contado. En este mismo libro formarán al fin de cada año un balance general de todas las operaciones de su giro. Se considera comerciante por menor al que vende directa y habitualmente al consumidor.

Obviamente por volúmenes y costos de transacción, las ventas al por mayor son más económicas que las ventas al por menor.

Esta distinción se hace porque hay que hablar de las obligaciones de los comerciantes, todas las obligaciones que señalaremos corresponden al comerciante al por mayor, ahora puede un comerciante al por menor sujetarse voluntariamente a estas obligaciones porque quien puede lo más puede lo menos. Y si soy un comerciante al por menor y quiero responder a un estándar superior de control puedo regirme por las normas de las empresas al por mayor.

Básicamente la ley impone 4 obligaciones para todos los comerciantes, independiente de que sean al por mayor o menor.

I. Llevar libros de contabilidad y de comercio

Art. 25. Todo comerciante está obligado a llevar para su contabilidad y correspondencia:

- 1°. El libro diario;*
- 2°. El libro mayor o de cuentas corrientes;*
- 3°. El libro de balances;*
- 4°. El libro copiador de cartas.*

Acá nos retrotraemos al mensaje del CdC, donde se establece que la contabilidad es el reflejo del alma del comerciante. La contabilidad es el elemento indispensable para determinar el resultado de las operaciones que el comerciante realiza día a día.

Por un lado, refleja cuales son todas las operaciones que están realizando, es decir, cual es el estado de resultado, como va el negocio. Y al mismo tiempo hace constar y comprobar lo que es la deuda. Hay una cuenta de haber y de deber, las cuentas en la contabilidad siempre tienen que estar absolutamente ordenadas.

Además, los libros de contabilidad hacen plena prueba respecto de los juicios que se refieren a operaciones de comercio. Hacen plena prueba, en favor o en contra.

Para esta contabilidad se deben llevar algunos libros, algunos son obligatorios y otros facultativos. En el artículo 25 están los libros obligatorios.

- a) Libros diarios: es el libro mas importante de todo contador. En este se anotan cronológicamente día a día todas las operaciones mercantiles que ejecuta el comerciante.
- b) Libro mayor: Es un libro integrado por distintas cuentas, están:
 - Cuentas personales: donde se anotan a las personas con las cuales el comerciante mantiene negocios.
 - Cuentas reales: donde se anotan los objetos particulares que forman parte del negocio.
 - Cuentas de orden: son registros de valores que no pertenecen al negocio o al sujeto y que se mantienen en deposito o en garantía.
- c) Libro de balances e inventario: Es muy importante. Es el libro de balances e inventario. Esta definido en el artículo 29 del CdC y tiene una doble función, en primer lugar aquí se anotan el inventario de los bienes físicos y el resumen de los activos y pasivos con las ganancias y perdidas. Este libro es muy importante porque es el corazón del negocio. Si lo que ingresa

es mas de lo que sale hay superávit, sino déficit. El inventario es el stock que tienen las empresas, es el que nos hará saber si tenemos o no para vender. Se debe tener siempre un stock o cantidad reservada. En este libro se determina cuanto es el stock que tengo y la cantidad de bienes con las que cuento para ejercer mi negocio y cuantos tendré que comprar, cada cuanto, etc.

Art. 29. Al abrir su giro, todo comerciante hará en el libro de balances una enunciación estimativa de todos sus bienes, tanto muebles como inmuebles, y de todos sus créditos activos y pasivos. Al fin de cada año formará en este mismo libro un balance general de todos sus negocios, bajo las responsabilidades que se establecen en el Libro IV de este Código.

- d) Libro copiador de cartas: Que es el archivo donde se guardan todas las cartas enviadas y recibidas. Todo se hace digitalizado.

De conformidad a las normas que regulan el sistema tributario chileno, estos libros de contabilidad deben estar en castellano, en virtud del artículo 26. Art. 26. Los libros deberán ser llevados en lengua castellana.

Además, de conformidad a lo dispuesto en el DL 3.475 que establece el impuesto de timbre y estampilla, requiere de timbraje, lubricación y autorización. La contabilidad para que sea aceptada y tenga validez frente al SII debe estar autorizada por ella.

La legislación tributaria impone ciertas obligaciones respecto a los libros de contabilidad que son necesarias mencionar.

- a) Artículo 97 N°6 del CTri, La no exhibición de libros de contabilidad o de libros auxiliares y otros documentos exigidos por el Director o el Director Regional de acuerdo con las disposiciones legales, la oposición al examen de los mismos o a la inspección de establecimientos de comercio, agrícolas, industriales o minerales, o el acto de entorpecer en cualquier forma la fiscalización ejercida en conformidad a la ley, con multa de una unidad tributaria mensual a una unidad tributaria anual.
- b) Una segunda obligación tributaria está contenida en el art. 97 N° 7. El hecho de no llevar la contabilidad o los libros auxiliares exigidos por el Director o el Director Regional de acuerdo con las disposiciones legales, o de mantenerlos atrasados, o de llevarlos en forma distinta a la ordenada o autorizada por la ley, y siempre que no se dé cumplimiento a las obligaciones respectivas dentro del plazo que señale el Servicio, que no podrá ser inferior a diez días, con multa de una unidad tributaria mensual a una unidad tributaria anual. Esto se relaciona con las normas internacionales de como llevar la contabilidad que son las IFRS.

La pérdida o inutilización de libros se sanciona con una multa que va desde el 1% al 30 % del capital efectivo de la sociedad. Esto obviamente no ocurre ahora porque la contabilidad es digital por ende no se pierde.

Principios de la contabilidad

El secreto o inviolabilidad de la contabilidad

**Pregunta de prueba*

Esto es muy importante. Los inspectores o revisores del SII, pueden fiscalizar y revisar todos los libros, pero manteniendo el secreto profesional.

Existe la inviolabilidad de la contabilidad, el secreto de la contabilidad. Este secreto existe porque si se revela puede afectar a la competencia. Porque si yo estoy exhibiendo todos mis libros, muestro mis números y lo que tengo.

La competencia si sabe estos números puede salir al mercado a vender la información de la empresa y tiene información privilegiada y esto puede hacer incurrir en alguna especie de atentado contra la libertad de competencia o la competencia desleal.

Por eso existe la inviolabilidad de la contabilidad, es decir, salvo respecto del SII, no existe una posibilidad de pedir una revisión total de los libros y por lo mismo el artículo 43 señala:

Art. 43. La exhibición parcial de los libros de alguno de los litigantes podrá ser ordenada a solicitud de parte o de oficio. Verificada la exhibición, el reconocimiento y compulsas serán ejecutados en el lugar donde los libros se llevan y a presencia del dueño o de la persona que él comisione, y se limitarán a los asientos que tengan una relación necesaria con la cuestión que se agitare, y a la inspección precisa para establecer que los libros han sido llevados con la regularidad requerida. Sólo los jueces de comercio son competentes para verificar el reconocimiento de los libros.

Solo procede la exhibición parcial de los libros de contabilidad, a través de un juicio y no la exhibición total. Y solo respecto a operaciones que digan relación con el juicio.

Esto quiere decir que aun cuando sea materia judicial, no existe una exhibición total de los libros de contabilidad, solo se puede decretar una exhibición parcial de los libros y solo respecto de aquellos que contengan las obligaciones que se refieren a la materia del juicio y no operaciones distintas.

Aquí se ve la protección al comerciante. Si somos comerciantes debemos llevar la contabilidad de manera fidedigna y muy bien., pero eso no significa que se deba andar mostrando a todo el mundo. Ni siquiera el juez puede decretar la exhibición total de la contabilidad.

Por cierto, entonces, si estamos en un juicio y le pido a la contraparte como medida probatoria la exhibición de la contabilidad para efectos de acreditar las operaciones comerciales en materia del juicio, el tribunal dirá, “traslado”, pero la contraparte dirá que no porque no se puede pedir la visión general de la contabilidad de ciertos años, sino que solo se puede pedir la exhibición parcial de aquellas partidas en que se contengan las obligaciones.

Por ejemplo no puedo pedir la exhibición de la contabilidad a mí contraparte de los años 2018 y 2019 que se refiera a determinadas obligaciones en materia del juicio, porque en ese caso estaríamos pidiendo la contabilidad total de aquellos años cuestión que no se puede, sino que solamente se puede pedir la exhibición parcial de una determinada materia pero no aquella general del año completo.

Por ultimo, muchas veces no tenemos el registro contable de lo que nos piden, entonces si me piden exhibir las partidas en donde se contengan las operaciones de venta de una empresa X, aquí hay un serio problema. En este caso, recordemos que la contabilidad hace plena prueba en favor o en contra, y en este supuesto seria en contra. Habrá una multa con el SII.

Sin perjuicio, existen 3 excepciones a la exhibición general de los libros en materia constitucional, por ende en virtud del decreto de la contabilidad o de la inviolabilidad de la contabilidad, no se puede pedir la exhibición total, salvo;

- 1º. Tratándose de la sucesión universal del comerciante, es decir, en caso de una herencia.
- 2º. Tratándose de una comunidad de bienes, también están obligados a exhibir la totalidad de la contabilidad.
- 3º. En la liquidación de las sociedades legales o comerciales. La liquidación de la sociedad es para ver cuales son todos los bienes que tenia la sociedad, esto se aplica incluso para la sociedad conyugal.
- 4º. Casos de liquidación concursal. De conformidad a lo dispuesto en el artículo 57bde la ley N° 20.720 existe la obligación del liquidador de incautar todos los libros de contabilidad del deudor. No existe contabilidad parcial en ese caso.

Entonces, el principio general es la inviolabilidad de la contabilidad. La contabilidad debe ser llevada completamente, llevada en detalle y si el SII me pide algo se lo debo mostrar, esto porque no solo el SII, sino que además si quiero vender mi empresa y llega un abogado a cargo de la operación me dice que va a revisar la empresa pidiendo la contabilidad.

Por esto la contabilidad es fundamental y se protege, para proteger al comerciante.

24 de septiembre

La contabilidad es lo que nos hará ganar o perder un juicio.

La contabilidad hace plena prueba a diferencia de los instrumentos privados en derecho civil. La contabilidad hace plena prueba respecto de su contenido, respecto del hecho de haberse otorgado y respecto de las partes comparecientes, sobre todo cuando se trata de juicios entre comerciantes.

Ya sabemos los requisitos tributarios que exige el servicio para que los libros estén bien llevados, que son que estén en castellano, que se ordenen cronológicamente, etc. Se refiere a un sistema aceptado. Esto es tan relevante que una de las grandes maneras que tiene el comercio en nuestro país de acreditar sus movimientos, las compras, etc, es a través de las facturas.

Todos conocemos las facturas, es una especie de boleta. Cuando se presta un servicio se emite la correspondiente factura. La factura tiene 2 características; tiene que dar cuenta de la prestación de un servicio o de la entrega de una mercadería.

Antiguamente lo que se establece es que la factura debe dar cuenta de la prestación de un servicio o de las mercaderías y además tiene que tener el acuso recibo, es decir, debe ser recibida por el destinatario. Solo de esa manera, cuando conste el recibo de la factura se podría eventualmente cobrar en sede judicial. Sin embargo desde hace unos años ya no hay facturas materiales, ahora existe la facturación electrónica. Ya no se necesita el acuso recibo o la firma del deudor de la factura, sino que se hace automáticamente a través del SII.

Tener un sistema de contabilidad es caro, pero no es caro para empresas porque permite tener todo ordenado. Es tan importante tener la contabilidad al día, que es la única manera que tenemos para sacar adelante un juicio, es probar y contar con las herramientas.

Esta contabilidad, es la historia personal de la empresa y no queremos que sea conocida por todos. No puede ser una exhibición total, solo parcial y solo de aquellas materias propias del juicio. Salvo en los casos que vimos. Respecto a estos casos hay que recordar que la personalidad jurídica se mantiene respecto de la liquidación.

En cuanto al tiempo en el que se debe llevar esta obligación, la ley no lo determina, pero es todo el tiempo que sea necesario mientras este cualquier asunto pendiente.

Además se añade que esta obligación recae también sobre los herederos. Si se recibe por herencia la contabilidad de una empresa, sea cual fuere, se tendrá que guardar porque los herederos representan al causante para todos los efectos sociales.

Problema jurídico en cuanto a la contabilidad

Es un problema de bastante presencia publica actualmente sobre todo entre el ministerio publico y algunos jueces civiles con respecto al tema de la contabilidad.

Art. 41. *Se prohíbe hacer pesquisas de oficio para inquirir si los comerciantes tienen o no libros, o si están o no arreglados a las prescripciones de este Código.*

Este artículo esta redactado en términos prohibitivos. Se prohíbe hacer pesquisas de oficio para ver si se lleva la contabilidad y si esta bien llevada.

a) En sede penal

Por ejemplo un juicio de naturaleza penal, aquí el ministerio publico podría hacer esto? ¿podría el ministerio publico llegar a la oficina de alguien y incautar los libros de contabilidad? Esto se da para un caso penal.

Hay algunas leyes en particulares que parecieran dejar abierta la posibilidad, como son la ley 20.000 de trafico de drogas que permitiría hacer esto. Y también todo lo que es la ley del *compliance* o responsabilidad penal de la empresa, podría llegar a estas facultades de requisar papeles de la contabilidad.

b) En sede civil

Si llevamos esto a la parte civil, el juez civil, ¿puede actuar de oficio?, en los juicios civiles rige el principio dispositivo, sin embargo, nos encontramos con las medidas para el mejor resolver en materia civil.

Las medidas para mejor resolver el artículo 159 del CPC, señala que los tribunales solo dentro del plazo para dictar sentencia podrán dictar medidas para mejor resolver y entre ellas hay algunas que son: N°1: la agregación de cualquier documento que estimen necesario para esclarecer el derecho de los litigantes.

¿Puede un juez civil de conformidad a lo dispuesto en el artículo 159 N°1 decretar que se traigan a la vista los documentos de la contabilidad del año 2019?

No se puede pedir una exhibición total, sino que son parcial y de aquellas materias que son parte de lo que se necesita saber. Por ende, uno se puede oponer por 2 cosas:

- 1º. Me opongo porque no procede por la norma
- 2º. La petición esta mal hecha

- 3º. Las medias precautorias de mejor resolver no tienen por objeto arreglar la prueba, ya que la prueba que se debió haber rendido durante el probatorio. Si ninguna de las partes pidió o se dejó sin efecto la exhibición de un documento el juez no puede venir a apelar la prueba a la otra parte. Las medidas de mejor resolver solo son para complementar una prueba rendida.
- 4º. Por último en ese incidente dejaría transcurrir 20 días porque la ley establece que después de 20 días de decretada una medida para mejor resolver que no se cumplió, se tiene por no decretada. Entonces se genera el incidente por 20 días y después se pide que se tenga por no decretada.

c) Tribunales arbitrales

Por ejemplo, se acuerda en un juicio en un tribunal de arbitro arbitrador y como no esa sujeto a un procedimiento legal, ¿que pasa si me pide la exhibición de los documentos?

El arbitro arbitrador no se somete a las normas del procedimiento ni en cuanto a la tramitación ni en cuanto al fallo.

No se puede también porque lo prohíbe el artículo 41. Da lo mismo que el juez o arbitro diga lo contrario. La ley hay que defenderla. No hay que dejarse intimidar por los jueces, por algo existe la inviolabilidad de la contabilidad.

28 de septiembre

Habíamos visto que la primera obligación de los comerciantes era la contabilidad, la analizamos. Vimos cuando procede y los requisitos. También vimos el valor probatorio, además vimos el secreto de la contabilidad, incluso vimos que la norma prohibitiva del artículo 41.

Vimos ejemplos y casos prácticos del artículo 41. Cuestión que rige para todo tipo de procedimientos y todo tipo de adjudicaturas.

Art. 41. Se prohíbe hacer pesquisas de oficio para inquirir si los comerciantes tienen o no libros, o si están o no arreglados a las prescripciones de este Código.

Aquí, la gran obligación es llevar la contabilidad. Y que ahora se puede hacer con sistemas mas simples y digitalizados.

II. Inscribir documentos en el registro de comercio

La segunda obligación de los comerciantes es la de inscribir ciertos documentos en el registro de comercio. Los comerciantes, sea cual fuere el tipo de comerciantes, es decir, si es individual o empresario, o sea con prescindencia de la estructura que se usa para realizar su comercio, tiene que inscribir ciertos documentos en el registro de comercio para efectos de publicidad.

Para efectos que los terceros sepan con quien están contratando. Esta publicidad se logra y se materializa a través del registro de comercio que esta creado especialmente para este efecto.

Normalmente, lo usual es que el registro de comercio sea llevado por el mismo conservador de bienes raíces. El CBR no solo lleva un registro de propiedad, sino que además tiene un registro de hipotecas y gravámenes, y un registro de prohibiciones e interdicciones de enajenar.

Además puede haber un registro de pertenencias mineras o conservador de minas o/y un registro de comercio.

En el caso del CBR de Santiago funcionan todas estas cosas juntas y hay un registro propio que lleva el conservador de bienes raíces de Santiago.

Documentos que deben inscribirse

Son aquellos que si no se inscriben se pueden producir problemas gravísimos.

Titulo II - de las obligaciones de los comerciantes - 1. De la inscripción de documentos

Art. 22 En el registro del comercio se tomará razón en extracto y por orden de números y fechas de los siguientes documentos:

- 1º. De las capitulaciones matrimoniales, el pacto de separación de bienes a que se refiere el artículo 1723 del Código Civil, inventarios solemnes, testamentos, actos de partición, sentencias de adjudicación, escrituras públicas de donación, venta, permuta, u otras de igual autenticidad que impongan al marido alguna responsabilidad a favor de la mujer.

La naturaleza de este primer grupo de actos o contratos que deben ser inscritos en el RCom, se refieren básicamente con dar a conocer a terceros que están contratando. Lo que en el fondo el legislador esta estableciendo es que los terceros que contratan con este comerciante sepan si hay relaciones de familia que puedan afectar la libre disposición de los bienes por parte del comerciante para responder de sus deudas.

Se dice que es cualquier acto que imponga una responsabilidad del marido en favor de la mujer, pero se entiende que esto ya es reciproco. Porque si se impone una obligación de la mujer en favor del marido, también se aplica.

En todo caso, se trata de normas de orden económico y por eso afectan al comercio. Se debe saber cuando vamos a contratar con esta determinada persona que puede hacer prestaciones de naturaleza familiar y que tiene una obligación de carácter económico en favor del cónyuge que limite sus bienes.

- 2º. De las sentencias de divorcio o separación de bienes y de las liquidaciones practicadas para determinar las especies o cantidades que el marido deba entregar a su mujer divorciada o separada de bienes.

Nuevamente esta redactado en una manera rara. Como si fuera el marido el que siempre es el deudor de entregarle una suma de dinero a la mujer. Esto también es recíproco, o sea, cualquier tipo de cantidad que el marido o la mujer le deba entregar a su cónyuge o ex cónyuge, si se ha divorciado o separado de bienes.

- 3º. De los documentos justificativos de los haberes del hijo o pupilo que está bajo la potestad del padre, madre o guardador.

Es decir, todo lo que pueda afectar los bienes desde una perspectiva económica del comerciante, sea hombre, mujer o un menor adulto que tiene capacidad ejercicio. Todos estos elementos que puedan alterar la capacidad económica de este comerciante tienen que ser inscritos en el RGom.

Esto muchas veces se olvida cuando se tramita un juicio de divorcio. Se obtiene el divorcio vincular, y se inscribe en el RC, que corresponde. Pero se olvida que esa misma sentencia se debe inscribir en el RCom, para que la persona no quede supeditada.

Por ejemplo, me divorcio en ese minuto si uno quiere realizar un trabajo bajo su patrimonio propio, cualquier persona le va solicitar la inscripción de este documento de divorcio o bien la comparecencia del ex cónyuge.

- 4º. De las escrituras de sociedad, sea ésta colectiva, en comandita o anónima, y de las en que los socios nombraren gerente de la sociedad en liquidación.

Sea cual fuere el tipo de sociedad. Tienen que inscribirse las sociedades porque las sociedades se forman, existen y prueban por EP inscritas y publicadas.

Todas las sociedades en la actualidad se forman, existen y prueban por EP, la cual se debe inscribir en el RCom, y publicar además en el diario oficial. Es un sistema complejo y que se queda atrás.

En la actualidad existen las sociedades en un día, que es básicamente inscribir un tipo de sociedad en el ministerio de economía, con ciertos requisitos y cumpliendo ciertas estructuras. Sin embargo, estas sociedades en 1 día tienen muchos problemas de publicidad.

Lo importante es que las EP de las sociedades deben estar inscritas. Por ende, cuando vaya a contratar no solo debo pedir la EP de la sociedad, sino que además la inscripción vigente de la sociedad.

Esto es porque la EP puede ser muy antigua, y nos encontramos con 2 problemas;

- a) Primero porque las EP para que tengan validez o vigencia deben ser entregadas por el ministro de fe competente. Una vez entregada esa EP, la otorgara el notario dentro del año contado la fecha de ña expedición de la escritura. Si hoy 28 de septiembre de 2020 suscribimos cualquier tipo de EP, desde ese minuto tengo 1 año para pedir al notario una copia autorizada de esa EP, la cual será suficiente para entregarla a la otra parte contratante. Es decir, tengo hasta el 28 de septiembre del 2021 para pedirle al mismo notario ante quien se otorgo la EP una copia autorizada de la misma. Esto porque los notarios conservan los protocolos de las EP por un año. Después del año, se pide al archivo judicial, vencido el plazo de 1 año que tienen los notarios para llenar estos protocolos, uno le pide la escritura al archivo judicial. El archivo judicial es importante para hacer los estudios de titulo.
- b) Entonces, puedo mandar la escritura, pero la sociedad no esta vigente. Puedo haber modificado la sociedad, por ende, lo que se hace es pedir la EP por una parte para saber cuales son los contenidos y además un certificado de vigencia que va a otorgar el RCom, en el cual va a decir, si es que esta escritura ha sufrido modificaciones y cuales son estas.

5°. De los poderes que los comerciantes otorgaren a sus factores o dependientes para la administración de sus negocios.

Hay que inscribirlos, y si no esta inscrito pueden haber problemas. Los poderes que se tienen de administración – que no son una cosa accidental o eventual – deben representarse y estar inscritos.

Todos y cada uno de los numerales del artículo 22, para efectos de publicidad tienen que estar inscritos y con esto no se puede alegar conocimiento en contrario. No se puede alegar que no sabia.

En cuanto al plazo para inscribir estos documentos, la ley en el mismo artículo señala que deben practicarse en el plazo de 15 días contado desde el otorgamiento de los documentos. No es un plazo fatal en todo caso, porque por ejemplo en las sociedades el plazo es de 60 días.

III. Inscribirse en determinados registros

No es una obligación que rija para todos los comerciantes. Hay algunos comerciantes que se van a dedicar a determinados ADC que deben inscribirse en determinados registros.

Algunos ejemplos son;

- a) Martilleros. Para poder ejercer su función tienen que estar inscritos en un registro que al efectos establece el ministerio de economía. Es obligación del abogado saber si hay que inscribirse o no en un registro.
- b) Embotelladores de Vino y Champaña. Se entiende que todo productor de bebidas alcohólicas que sean comerciantes al por mayor deben registrarse en una dirección especial del SII. Es decir, además de cumplir con la contabilidad y la inscripción de documentos en el RCom, además si me dedico a la venta de alcohol, tengo que inscribirme en un registro especial que al efecto lleva la dirección del SII.
- c) Bolsas de Valores.
- d) Corredores de Bolsa.

IV. Pagar patente municipal

Obligación que se le impone a todos los comerciantes. Es una obligación cara. Es para todos los comerciantes.

De conformidad al artículo 23 de la Ley de Rentas Municipales, el ejercicio de toda profesión, oficio, industria, comercio o cualquier actividad lucrativa secundaria o terciaria, sea cual fuere su denominación, esta sujeto a una contribución de patente municipal.

El ejercicio de toda profesión requiere pagar patente municipal. Las patentes se pagan porque la ley establece que toda actividad lucrativa de los sectores secundarios o terciarios lo deben hacer.

La patente municipal se calcula en base a las rentas que uno va obteniendo. Pero hay empresas que no tienen rentas, sino que hay sociedades nuevas. Acá es donde los abogados debemos asesorar al cliente y decirle que no pongan empresas con mucho capital porque cobran en función al capital.

Una sociedad nueva no porque tiene un capital grande es una empresa mas rentable, o mas fiable a los ojos de la banca. Eso no es así. Porque a las empresas les prestan plata por la antigüedad y no por el capital.

En caso alguno, se considera el capital de la sociedad, sino que para un crédito se considera el flujo, el nivel de ingresos, los movimientos empresariales, etc.

Una patente comercial es una autorización para ejercer el comercio, por ende se transfiere con el establecimiento de comercio. Si el establecimiento de comercio que se esta pagando por esta patente, cambia de dueño, se transfiere. Esta es casi una obligación *popter rem*, no sigue al titular del inmueble, sino que sigue el dueño del establecimiento de comercio.

Por ejemplo, los cafés con piernas, ya no existen patentes para estos cafés. Desde el año 2000 que ya no se emiten, sin embargo siguen transfiriéndose estos permisos.

A transferencia de la patente jurídicamente la patente es una contribución, es un tributo de carácter municipal y esa es su naturaleza. En el fondo lo que se hace es autorizar transferir un tributo. No obstante la naturaleza impositiva, la ley faculta su transferencia solo en el evento de que se enajene el establecimiento. La patente no se puede vender sola, siempre debe ser en conjunto con el establecimiento de comercio gravado con esa patente.

Este concepto es digno de una tesis. La noción de que se permite la enajenación de las patentes. Es como vender un impuesto. Es muy extraño, pero se entiende. Pero entonces mas que un impuesto seria una autorización de funcionar, seria el pago de un tributo que me permite funcionar.

PERSONAL DEL EMPRESARIO DE COMERCIO

Mientras mas compleja se hace la realidad del comercio el trabajador no puede ejercer solo su comercio, sino que se tendra que empezar a rodear de colaboradores y contratar servicios de diversas personas.

Por ejemplo, si tengo una cartera de clientes, con el tiempo esta cartera se fue diversificando. Uno siempre parte tomando casos de gente conocida, y de repente esto crece y ya no se tiene tiempo de ir a tribunales todos los días, por lo que uno se consigue un procurador.

Para esto surge la necesidad de tener mas personas y la ley reconoce un grupo de tipos de personas, que se pueden agrupar en 2 categorías.

I. Colaboradores o agentes dependientes del empresario de comercio

Son dependientes y que se representan en 2 grupos:

- a) Factores o gerentes: son los mas importantes.
- b) Mancebos o dependientes: personas que trabajan en la misma empresa.

Sea cual fuere, todos ellos están unidos al empresario de comercio en virtud de un vínculo jurídico laboral, es decir, en virtud de un contrato de trabajo. El dependiente mas simple dentro de la estructura de la empresa, es decir, el trabajador menos calificado en materia profesional tiene la misma relación jurídico-laboral que el gerente de la empresa, que es el contrato de trabajo.

Es mas, en ciertas circunstancias no obstante tener un vínculo de naturaleza laboral, el gerente va a incluso poder representar a este empresario de comercio. Los factores o gerentes representan o pueden representar a este factor de comercio, no así los dependientes.

II. Colaboradores o auxiliares independientes

Esta integrado por todos aquellos que prestan un servicio, pero no hay un vínculo de subordinación y dependencia. No hay un vínculo laboral que una a este colaborador o agente auxiliar con el empresario.

Pueden ser, los corredores de comercio, comisionistas, agentes de negocios, los martilleros. Es decir, todo aquel que presta colaboración para el desarrollo del empresario de comercio pero que no esta unido con un contrato de trabajo, sino con otros vínculos contractuales. Por ejemplo, el contador externo, que no esta unido a un vínculo de subordinación y dependencia, hay un contrato de prestación de servicio.

Entonces, el empresario de comercio tiene estos dos grupos de personas, a los dependientes y a los independientes. Con los dependientes los une el vínculo jurídico laboral, es la relación de subordinación o dependencia que se mantiene con ellos.

Ahora bien, cuando se requiere que este personal pueda actuar en lugar del empresario de comercio (que la ley lo llama como "el principal"), se recurre a las figuras jurídicas de la representación y mandato.

El principal necesita tener a una persona para que lo represente para la ejecución de determinados actos y contratos, y en virtud de esta representación puedo recurrir a la figura del mandato. Y esta representación es esta figura jurídica en virtud del cual una persona ejecuta a nombre de otra y estando facultado para ello, un determinado acto o contrato, y los efectos de ese acto o contrato se quedan en el patrimonio del principal, es decir, de la persona representada y no del mandatario.

Ahora bien, las fuentes de la representación son la convención y la ley, y lógicamente en el derecho comercial, la que mas se ve es la convención, es decir, el acuerdo de voluntades en virtud del cual nombro a una persona como mi representante.

Ahora para que se produzca el efecto de la representación, para que este representante tenga la capacidad de representarme frente a los terceros, es decir, que los derechos y las obligaciones que nazcan de los contratos celebrados por este representante se radiquen en el patrimonio del principal, se requieren 2 presupuestos:

1º. Capacidad de representar.

Que el representante tenga la capacidad de representar. Recordemos que el mandato no confiere naturalmente al mandatario mas poder que el de efectuar actos propios de administración. El artículo 2132 del Código Civil establece que el mandato otorga las facultades ordinarias que corresponden a los actos de administración.

Por su parte el artículo 340 del Ccom señala: Art. 340. Los factores se entienden autorizados para todos los actos que abrace la administración del establecimiento que se les confiare, y podrán usar de todas las facultades necesarias al buen desempeño de su encargo, a menos que el comitente se las restrinja expresamente en el poder que les diere.

Es decir, el mandato no confiere en caso alguna mas facultades que realizar los actos de administración, como lo dice el artículo 2132 del Código Civil. Con todo, el artículo 340 lo explica y dice que tiene todas las facultades necesarias para la administración del establecimiento que se le ha conferido y no existe una limitación ya que esta redactado en términos muy abiertos. Pero salvo, aquellas que se restrinjan expresamente.

Es decir, cuando nuestro cliente necesite dar un mandato estamos hablando de un mandato para que lo representen.

La importancia de esto es que esta capacidad de representar que tienen los factores, especialmente los gerentes, comprende todas las facultades propias del giro, salvo aquellas que se limiten. Por eso, los errores que cometen los clientes son no limitar las facultades de los representantes, cuestión compleja que acarrea líos tremendos por la extralimitación del mandato.

2º. *Contemplatio domine*

Esta institución consiste en el hecho de hacer saber a la parte con la que se celebra el contrato que el representante esta actuando a nombre de un tercero.

Este elemento es fundamental, la *contemplatio domine* hace saber al tercero que esta actuando en representación de otro.

Siempre tenemos que poner en la comparecencia de que estamos actuando en nombre o representación de otro. Es mas, incluso en las comisiones de confianza, que son ciertas

operaciones que se pueden realizar con los bancos bajo reserva y confidencialidad, se debe decir en representación de otro.

Lo ideal es saber con quien estamos contratando. De lo contrario, podríamos pretender que estamos celebrando el acto con el representante, y si hay un incumplimiento es la esfera contractual voy a intentar accionar en contra del representante.

Por eso, para que el efecto de la representación se le produzca al tercero que esta contratando es necesario estos dos elementos, tanto la capacidad para representar como la *contemplatio domine*.

Si no, nos quedamos con el artículo 328, que dice: *Art. 328. Los factores o dependientes que obraren en su propio nombre quedan personalmente obligados a cumplir los contratos que ajustaren.*

Esta es la norma inicial, los factores o dependientes que actuaren a nombre propio serán obligados personalmente a cumplir los contratos que celebren. El principio básico es que el representante responde personalmente.

Después el artículo dice que si quedara obligado el principal en 4 casos. *Pero se entenderá que los han ajustado por cuenta de sus comitentes en los casos siguientes:*

- a) Cuando tal contrato corresponda al giro ordinario del establecimiento que administran.

Por ende, si compro 100 toneladas de tela para una empresa textil, no me preocupo porque como es parte del giro se entiende que se hace como representante de la empresa.

- b) Si hubiere sido celebrado por orden del comitente, aun cuando no esté comprendido en el giro ordinario del establecimiento.

Es por orden del principal aunque no hubiese sido parte del giro del negocio. Por ejemplo, si vendo buzos, pero quiero ampliar mi giro a mascarillas y yo como principal le digo al representante que compre una maquina para hacer mascarilla. No es parte del giro, sin embargo, actuó bajo la orden del principal, y en ese caso los efectos del acto, aunque no sean del giro repercuten en el patrimonio del principal.

- c) Si el comitente hubiere ratificado expresa o tácitamente el contrato, aun cuando se haya celebrado sin su orden.

Se ratifica el acto ejecutado por el representante independiente si fue por orden del principal o no.

- d) Si el resultado de la negociación se hubiere convertido en provecho del comitente.

O sea, si por ejemplo me trajo utilidades liquidas de 5 millones de dólares anuales por un negocio que no teníamos, no puedo despedir al representante o pretender que pague los volúmenes del negocio.

La norma básica en esta materia esta en el artículo 2465 del Código Civil que es el derecho de prenda general.

Art. 329. En cualquiera de los casos enumerados en el anterior artículo los terceros que contratasen con un factor o dependiente pueden, a su elección, dirigir sus acciones contra éstos o contra sus comitentes, pero no contra ambos.

EL MANDATO COMERCIAL

Este mandato esta definido en el artículo 233 de CdC. *Art. 233. El mandato comercial es un contrato por el cual una persona encarga la ejecución de uno o más negocios lícitos de comercio a otra que se obliga a administrarlos gratuitamente o mediante una retribución y a dar cuenta de su desempeño.*

La ley habla de que una persona le encarga a otra la ejecución de uno o mas negocios lícitos de comercio. No existen los actos ilícitos de comercio, esos son delitos.

Habla de negocios lícitos porque no es porque se pueda encargar un negocio ilícito, sino que simplemente se refiere a negocios autorizados por el mandante, que tenga la legitimidad de poder realizar un ADC.

Ahora bien, de conformidad a la definición del artículo 233 el contrato siempre será mercantil, o la mercantilidad de este contrato se da por el hecho de que se tienen que ejecutar ADC.

Y lo establecen como un mandato siempre mercantil. Según la doctrina este mandato comercial es un acto mixto o de doble carácter porque puede ser mercantil para la parte que lo esta ejecutando pero civil para el mandatario o viceversa.

De conformidad a lo dispuesto en la ley existen 3 clases de mandato comercial:

I. La comisión

Si el mandato se refiere a uno o mas negocios expresamente determinados se llama comisión. Es decir, cuando no es un mandato general. Esta determinado en negocios que están absolutamente singularizados. (no individualizado, porque las cosas no se individualizan, sino que se singularizan)

Cuando se trata de un mandato donde hay uno o mas negocios que están perfectamente singularizados, estamos frente a una comisión mercantil. Si se trata de un mandato generalizado, por ejemplo el poder para representar en todas las compraventas estaríamos frente a un mandato.

Es decir, no es que el mandato y la comisión sean distintos, sino que se diferencian simplemente en el objeto en el cual recae el contrato.

II. El mandato de los factores o dependientes del comercio

Este personal dependiente eran los factores o gerentes, y los mancebos o dependientes. El factor, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 237;

Art. 237. Factor es el gerente de un negocio o de un establecimiento comercial o fabril, o parte de él, que lo dirige o administra según su prudencia por cuenta de su mandante.

Acá el que toma las decisiones bajo su prudencia es el factor o gerente.

Denominanse mancebos o dependientes los empleados subalternos que el comerciante tiene a su lado para que le auxilien en las diversas operaciones de su giro, obrando bajo su dirección inmediata. El mandante toma el nombre de principal con relación a sus factores o dependientes.

III. La correduría

La correduría, de que se ha tratado ya en el Título III del Libro I.

Art. 48. Los corredores son oficiales públicos instituidos por la ley para dispensar su mediación asalariada a los comerciantes y facilitarles la conclusión de sus contratos.

1 Octubre

Estábamos viendo el personal del comerciante, específicamente a estos factores o gerentes dependientes.

Esta representación del 3ero para que produzca todos los efectos en el patrimonio del principal debía cumplir con 2 cosas que era la capacidad y la *contemplatio domine*.

Siempre es importante informar al 3ero que actuó en representación de otro, sino puedo quedar personalmente obligado.

Este factor según el artículo 237 es el que dirige o administra con su prudencia el negocio por cuenta del mandante. Si contrato a un gerente o factor es importante que tenga la autonomía para realizar el trabajo. La idea es ir delegando.

La empresa le fija las directrices en virtud de las cuales esta persona tiene que ejercer su cargo, pero tiene la plena libertad para ejercerlo. Obviamente los riesgos y todo lo que se produce respecto a ese trabajo, repercute en el patrimonio del principal o mandante.

Se contrata al gerente en virtud de la prudencia que tiene esta persona en su actuar, y si es imprudente obviamente también es problema mío que lo contrate. Por eso es importante la externalización de algunos servicios para evitar contratar y que además existan las empresas y/o las gerencias de recursos humanos.

Este gerente, que en realidad es un mandatario con facultad de administración, de conformidad al artículo 240 tiene todas las facultades necesarias para ejercer el giro de la empresa. Todas aquellas que son facultades ordinarias o normales.

Además este mandato mercantil para que tenga plenos efectos y de conformidad al artículo 339 debe constar por EP y debe inscribirse en el RCom, es decir, hay una diferencia con el mandato civil porque el mandato será solemne en la medida en que el acto o contrato que se celebre tenga también estas solemnidades, de suerte tal que si el acto que se celebra requiere también una EP, el mandato que se confiere para celebrarlo también deberá cumplir con aquellas solemnidades.

Pero acá estamos ante un mandato mercantil, y este mandato por disposición expresa del artículo 339 y en relación con el artículo 22, debe ser otorgado por EP.

La Escritura Publica es distinto al Instrumento publico. El IP es aquel otorgado por competente funcionario según dice la ley. Las EP se otorgan ante notario, por ende, la diferencia entre la EP y un instrumento autorizado ante notario publico, es que la EP es aquella que se otorga ante notario, no es una simple autorización de firma, porque en ese caso el notario simplemente esta dando cuenta de que comparecieron unas personas y que estas son sus firmas de los comparecientes pero no puede dar fe de nada de lo que se señala. La EP que se otorga ante notario hace plena prueba de 2 cosas, en primer lugar, de la fecha y entre las partes del contenido de la escritura. Ese es el valor probatorio de las EP, no solo del hecho de haberse otorgado en la fecha que se indica en ella, sino que además hace plena prueba del contenido, pero respecto de las partes, no respecto de terceros.

Ahora, la gracia además es que la EP, se tiene que protocolizar y se guarda en los registros del notario. Es decir, forma parte de aquellos instrumentos que el notario debe protocolizar y firmar en estos libros.

¿Como distinguirlos? Hay elementos muy fáciles para esto, primero las EP solo están escritas en letras, ni siquiera en números. Pero lo mas importantes en que la parte superior siempre esta el repertorio que es en el cual se incorpora y el primero que comparece en la escritura no son las partes, sino el notario, y dice “ante mi...”.

Esa EP es la que necesitamos para otorgar este mandato, porque este mandato se prueba de esta manera. Además, nunca se debe firmar un contrato con un mandato si no se ha revisado la vigencia del mismo, porque se puede no saber si el mandato esta vigente.

Quienes pueden ser gerentes

Primero obviamente hay un tema de capacidad. En este caso, además los que tienen la libre administración de sus bienes, y además los mayores de 18 años también pueden, de suerte tal que también podrían ser contratados como gerentes.

Pero, un menor de 18 si puede ser gerente, porque menor de 18 años puede celebrar un contrato de trabajo. Si un menor de 16 años con autorización de sus padres para poder trabajar, ¿puede ser gerente?, pero no se hace porque se supone que se contratan en base a su prudencia, pero si puede.

Facultades del factor

Acá se requiere una EP para la celebración, y esta EP debe estar inscrita. Si no se cumple con esto, no se celebra el acto o contrato. Sin embargo, dentro de estas facultades que establece la ley el código mismo ha regulado en los arts. 340 y ss., y señala que esta omisión de inscripción o omisión de la EP no acarrea la nulidad del acto o contrato celebrado.

Lo importante es que si celebramos una EP y no tenia mandato o ese mandato no estaba inscrito, no necesariamente acarrea la nulidad. Pero vamos a tener que ir a juicio para probar la eficacia, la vigencia, el reporte del beneficio final al mandante, etc.

Dentro de las facultades sabemos que están las generales que son las propias del negocio, y nosotros podemos asimismo enumerarlas. Lo importante es establecer las prohibiciones que tiene este factor o gerente.

Porque como tiene facultades muy laxas, es decir, todas aquellas habituales para la administración del negocio según su prudencia, lo que mejor conviene es determinar aquellas cosas que no queremos que haga, por ejemplo, capacidad de endeudamiento, que no pueda celebrar contratos de garantía para que no pueda obligar a la empresa a constituir una prenda o hipoteca, etc.

Si quiero limitar las facultades de este mandante que actúa bajo su prudencia las voy a establecer, muy a contrario sensu de lo que se entiende en relación con que debemos decir lo que se puede hacer, en verdad mas conveniente resulta limitar aquellas cosas que no queremos.

Artículo 329, establece la forma de hacer efectiva la acción que tiene el principal en contra de este factor o gerente cuando este ha actuado a su nombre y que corresponden a las mismas acciones que se establecen en el derecho civil para la extralimitación de las facultades del mandatario, por tanto, las sabemos.

Art. 329. En cualquiera de los casos enumerados en el anterior artículo los terceros que contrataren con un factor o dependiente pueden, a su elección, dirigir sus acciones contra éstos o contra sus comitentes, pero no contra ambos.

Acá estamos viendo dos instituciones de forma simultanea que es el mandato y el contrato de trabajo.

Derechos del factor

Tiene derecho a una remuneración. Artículo 336. Art. 336. Los factores y dependientes tienen derecho:

1°. Al salario estipulado, aun cuando por algún accidente inculpable no prestaren sus servicios durante dos meses continuos; salvo el caso en que, según convenio, se les pagare por jornales.

2°. A la indemnización de las pérdidas y gastos extraordinarios que hicieren por consecuencia inmediata del servicio que prestaren.

Obligaciones del factor

1°. Ejercer el encargo.

La principal obligación es ejercer el encargo hasta el termino del mismo. Obviamente respondiendo de dolo o culpa que incurra durante su ejecución.

Acá estamos ante una obligación de hacer, la cual debe hacerse de buena fe y si hay dolo o culpa, tendrá que responder bajo los estatutos de la esfera contractual

2°. Rendir cuentas

Los gerentes deben rendir cuentas. Nunca se debe relevar de la cuenta al mandatario. Quizás no en los mandatos de confianza.

Pero si se trata de un albacea o gerente siempre se debe rendir cuenta, sobre todo hay que recordar que esta la ley de responsabilidad penal por mala administración.

Si administro el patrimonio de terceros y respondo penalmente por la mala administración, con mayor razón vamos a tener que mantener la obligación de rendir cuentas.

3º. Cumplir con normas propias de comerciantes

Esta actuando por un comerciante. Es decir, la contabilidad, inscripción de documentos, etc.

Prohibiciones del factor

1º. Ejecutar por su cuenta los mismos actos cuya ejecución se les esta encomendando

En general, les esta vedado ejecutar por su cuenta los mismos actos cuya ejecución se les esta encomendando. Este es el principio genérico de todo mandato. No puede competir con su mandante.

Acá también están los principios generales del artículo 2144 y ss del Código Civil, básicamente que el mandatario no puede vender de lo suyo lo que se le ha ordenado comprar ni comprar para si lo que se le ha ordenado vender.

Estas normas que se establecen como principios generales de toda actuación de un 3ero, se mantienen para este caso, son normas de lealtad. Este deber forma parte del deber general en una sociedad.

2º. Delegar el mandato

Salvo autorización expresa en el documento constitutivo. No se puede delegar este mandato. Distinto es el caso del mandato judicial que se rige y restringe por el artículo 7 del CPC que son las facultades con las cuales se comparece.

Termino del mandato

1º. Por la revocación.

Ahora bien de debe distinguir 2 aspectos, el CdC hace una distinción respecto a si es un contrato a plazo fijo.

El artículo 332 dispone; Art. 332. *No es lícito a los factores o dependientes ni a sus principales rescindir sin causa legal los contratos que hubieren celebrado entre sí con término fijo, y el que lo hiciere o diere motivo a la rescisión deberá indemnizar al otro los perjuicios que le sobrevinieren.*

Acá se habla de la rescisión, pareciera que hubiera querido decir resciliacion. Porque al hablar de rescisión estamos hablando de nulidad, y de resciliacion hablamos de un acto de común acuerdo.

En todo caso, es que no se puede rescindir el contrato sin causa legal cuando se hubiere celebrado a plazo fijo. Y tratando de un contrato indefinido, cualquiera de las dos partes podrá darlo por terminado avisando con 1 mes de anticipación.

5 de octubre

Casos de problemas de gerentes que se van de empresas y se llevan las bases de datos y eventualmente se debe presentar algún tipo de acción.

De esta forma se puede ver por ejemplo, el caso en el que un gerente se retira de una empresa y continúa contratando con los clientes de esa empresa pero para efectos de su empleo como nuevo gerente en una empresa distinta. esto no sería correcto ya que en cierta sentido sería uso de información privilegiada y tampoco sería ético. Todas las gerencias tienen distintos grados de relevancia pero el gerente general es muy relevante.

El gerente general es muy importante, es en virtud de su prudencia como ejerce el cargo, de suerte tal que si nosotros vamos a darle fin a este cargo debemos preocuparnos de que este termino sea lo mas completo posible y conforme a derecho.

Que sea conforme a derecho se relaciona con que no sea solo en la terminación del mandato, sino que además conforme al cuerpo normativo del CdT, porque existe una dualidad. Y porque este gerente es un trabajador.

Un trabajador que recibe dentro de sus remuneraciones un porcentaje de acciones de la empresa o de participación de la empresa, ¿deja de ser trabajador y pasa a ser socio o solo es trabajador aun?

La ley reconoce que a los trabajadores se les puede otorgar la posibilidad de que opten a una parte de la participación o derechos in tener el control y tomar parte en las decisiones de la empresa, sino que son trabajadores que se ven beneficiados con el resultado del mismo.

Lo relevante es que cuando nosotros tengamos que contratar o finiquitar a un gerente general importante que trabaja con información completa y que trabaja con el conocimiento completo de la empresa, debemos tener cuidado de establecer este tipo de clausulas de confidencialidad, de no competencia, etc. Esa es la labor que debemos precaver cuando tenemos el control legal de una contratación.

Se debe mezclar esta doble dualidad entre el mandato civil y el contrato de trabajo.

La otra manera de terminar la veíamos en cuanto a que la ley distinguía entre dos situaciones, en primer lugar la ley distingue si existía o no contrato a plazo fijo o si existía un contrato indefinido.

2º. Contrato a plazo fijo.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 332; Art. 332. *No es lícito a los factores o dependientes ni a sus principales rescindir sin causa legal los contratos que hubieren celebrado entre sí con término fijo, y el que lo hiciere o diere motivo a la rescisión deberá indemnizar al otro los perjuicios que le sobrevinieren.*

Tiene que haber una causa legal para rescindir. El principio general es que sin causa legal no se puede hacer. Por ejemplo, si al gerente general lo contrate por 3 años, no lo puedo terminar antes, salvo por causa legal.

Ahora las causas legales que habilitan a terminar un contrato a plazo fijo son las siguientes: Art. 333. Sólo son causas legales de rescisión por parte del principal:

- 1º. Todo acto de fraude o abuso de confianza que cometa el factor o dependiente.
- 2º. La ejecución de algunas de las negociaciones prohibidas al factor o dependiente.
- 3º. 3a. Las injurias o actos que, a juicio del juzgado de comercio, comprometan la seguridad personal, el honor o los intereses del comitente.

Básicamente portarse bien. Este artículo habla de fraude o abuso de confianza, negociaciones prohibidas o injurias. O sea es un tema subjetivo. ¿Faltarle el respeto al mandante es causal legal? ¿Cuál sería el tribunal competente? Los dos tribunales tienen competencia dependiendo de quien demanda.

En todo caso esta el artículo 241 que dice; Art. 241. *El comitente no puede revocar a su arbitrio la comisión aceptada, cuando su ejecución interesa al comisionista o a terceros.*

El mandato y la comisión son lo mismo, pero cuando el mandato se refiere a una o mas operaciones mercantiles determinadas se denomina comisión.

Pues bien, dice este artículo que el comitente o el principal no puede revocar a su arbitrio la comisión aceptada, se hace la distinción recordando que el mandato es general y si estamos hablando de una o mas operaciones, estamos frente a una comisión.

No se puede revocar al arbitrio esta comisión que ha sido aceptada cuando su ejecución interesa al comisionista o a terceros. Al mandato general se le puede poner termino, pero en cuanto a la comisión, hay que tener ojo con las delegaciones de facultades porque el gerente general es alguien que se va de vacaciones por ejemplo. Este gerente no puede delegar su mandato, y en ese caso contrate a alguien mas en reemplazo de el gerente, que va a ejercer las facultades que se enumeran. Esto podría llegar a transformarse en una comisión y después no podría revocarse las estipulaciones de esa comisión si interesa a al comisionista o a un tercero.

Esta norma permite el fundamento por ejemplo de que uno firme pagares en blanco. Por esto el mandato en materia civil ya sabemos como termina. Pero si este mandato se transforma o se puede asimilar por su naturaleza a una comisión esta puede llegar a ser irrevocable.

Jamás se otorga un mandato para una comisión mercantil, sino que se dice “se otorga un mandato irrevocable en los términos del artículo 241 del CdC.”

Entonces no se puede revocar esta comisión mercantil que ha sido aceptada cuando su constitución interesa al propio comisionista o a un tercero (que es la empresa que puede realizar el cobro).

MANCEBOS O DEPENDIENTES

Dentro de los trabajadores o el personal auxiliar del comerciante se distingue entre los que dependientes e independientes y vimos que los independientes están los factores o gerentes, ahora tenemos a los dependientes o mancebos.

Los mancebos se refieren también a una persona que esta sujeta a una subordinación o dependencia respecto de este empresario de comercio pero que tienen un grado de relevancia para el ejercicio que no va de la mano con la dirección de la empresa, sino que simplemente es el trabajador dependiente de esta empresa.

Artículo 237 Denomínense mancebos o dependientes los empleados subalternos que el comerciante tiene a su lado para que le auxilien en las diversas operaciones de su giro, obrando bajo su dirección inmediata.

Es un personal subalterno que presta labores del giro de la empresa bajo la dirección inmediata de este comerciante, acá no estamos hablando del sentido de la prudencia. Como no tienen libertad para ejercer sus labores, actúa bajo la supervisión inmediata del empleador, y la regla general es que ellos no obligan a su empleador a menos que estos confieran expresamente la facultad de poder representarlos en determinados actos.

Tratándose de factores o gerentes, ellos representan al empleador y estaban estas dos figuras que era la capacidad y contemplatio domine.

Pero en este caso, los trabajadores subalternos no tienen facultad para obligar a su mandante o al principal, salvo que este le otorgue facultades expresas para determinadas operaciones dentro de su giro.

Facultades de los mancebos

Se distinguen 2 situaciones; la ley distingue entre los que son dependientes de ventas al por menor y mayor. Recordemos que esta distinción recae en si se vende directamente al consumidor final.

1º. Al por menor

Los dependientes encargados de ventas al por menor son los de grado mas subalternos que existen. Incluso están por debajo del rango de los que venden al por mayor, y estos dependientes de ventas al por menor no tienen ninguna actividad, y no tienen calidad alguna de mandatario y no obligan ordinariamente a su comitente en mas que aquellos actos en que están encargados.

No tienen facultades de mandatarios, no pueden hacer nada de lo que hemos visto.

2º. Al por mayor

Mantienen las mismas características, pero pueden tener ciertos grados mas altos en el ejercicio del giro. No con libertar. Como por ejemplo, cobrar el producto de las ventas y otorgar recibos a nombre del dependiente.

Ahora, sea cual fuere el tipo de este trabajador dependiente, tienen una única y gran limitación que es que su ejercicio solo podría entenderse que representa dentro de establecimiento de comercio.

La representación solo se extiende dentro del establecimiento y no fuera. Ahora, sise le pueden dar facultades especiales al trabajador, pero esas facultades deberán contar por escrito y anotarse en el registro de comercio en virtud del artículo 22, para saber si una persona cuenta o no con facultades para poder trabajar.

Entonces estos personales dependientes son el mas subalterno con el que uno se puede relacionar y tienen muy pocas facultades de representación y solo puede entenderse que actúan dentro del giro en el establecimiento comercial.

SITUACIÓN DE AGENTES INDEPENDIENTES

Entre los independientes están: Comisionistas, martilleros y corredores. Los martilleros y corredores ya sabemos que son.

Ahora nos interesa este comisionista. Recordemos que la comisión es una especie de mandato, cuando este mandato mercantil se refiere a una o mas operaciones comerciales absolutamente determinadas estamos frente a una comisión.

Para que exista la comisión mercantil, la primera diferencia es que hay un comitente y no un mandante, y un comisionado.

El comisionado no se encuentra vinculado con el comitente por ningún contrato de trabajo. No hay contrato de trabajo, por ende no hay vínculo de subordinación y dependencia. Simplemente es el encargo de uno o mas actos de comercio que tiene que ejecutar este comisionado.

Entonces para que proceda esta comisión debe:

1. Tratarse de operaciones absolutamente determinadas, de lo contrario seria un mandato.
2. Debe tratarse de operaciones mercantiles. Sino seria una comisión civil.

Forma de hacer el encargo

Esta comisionista puede dar su voluntad en forma expresa o tacita. Es expresa cuando dice de forma explicita que va a ejecutar el acto.

En cuanto a la tacita, recordemos el artículo 2515 del Código Civil, que contempla el caso del silencio y señala que las personas que por su profesión y oficio encargan negocios ajenos están obligados a declarar lo mas pronto posible si aceptan o no el encargo y trascurrido un termino razonable su silencio se mira como aceptación. Estamos hablando para el caso específico de personas que por su profesión u oficio administran negocios ajenos.

El artículo 243 del CdC, señala:

Art. 243. El comisionista puede o no aceptar a su arbitrio el encargo que se le hace; pero rehusándolo quedará obligado bajo responsabilidad de daños y perjuicios:

- 1º. A dar aviso al comitente de su repulsa en primera oportunidad.
- 2º. A tomar, mientras no llegue el aviso al comitente, las medidas conservativas que la naturaleza del negocio requiera, como son las conducentes a impedir la pérdida o deterioro de las mercaderías consignadas, la caducidad de un título, una prescripción o cualquier otro daño inminente.

Es decir, si representamos a empresas que por su profesión u oficio administran negocios ajenos y nos hacen un encargo, debemos contestar de inmediato. Porque sino genera responsabilidad. La primera obligación es avisar que se esta rechazando.

Si mi negocio es ser comisionista tengo que preocuparme de responder sino puedo generar la responsabilidad de estar respondiendo frente a 3eros por el simple hecho de no avisar.

Obligaciones del comisionista

Art. 245. *Aceptada expresa o tácitamente la comisión, el comisionista deberá ejecutarla y concluirla, y no haciéndolo sin causa legal, responderá al comitente de los daños y perjuicios que le sobrevinieren.*

El comisionista solo podrá no ejecutar esta comisión encargada cuando exista una causa legal que lo autorice para suspender o renunciar el encargo.

Por ejemplo, lo que se establece en el artículo 272;

Art. 272. Cuando la comisión requiera provisión de fondos, y el comitente no la hubiere verificado en cantidad suficiente, el comisionista podrá renunciar su encargo en cualquier tiempo o suspender su ejecución, a no ser que se hubiere obligado a anticipar las cantidades necesarias al desempeño de la comisión bajo una forma determinada de reintegro.

Que es que para efectos de ejecutar esta comisión necesite una provisión de fondos y esta no se le ha otorgado. Sería una causa legal que lo habilita para no ejecutar la comisión.

Pero resulta que por ejemplo me contratan para comprar inmuebles para la venta, y tengo la comisión en virtud de la cual no solo debo comprar los inmuebles sino que además los inmuebles deben estar aptos para el desarrollo del negocio, además me dicen que tengo un plazo de 4 meses para ejecutarlo. Si no lo logro ¿incumplí el contrato? Depende de los actos de la autoridad (que en este caso fue quien decreto la cuarentena)

La única causal para no cumplir con el encargo es una causal legal.

Forma del cumplimiento

Si se le han otorgado instrucciones precisas y exactas de como cumplir, debe atenderse ellas.

Pero en caso alguno, según el artículo 258, el comisionista podrá obrar contra las deposiciones expresas y claras del comitente.

Art. 258. El comitente puede declarar a los terceros que han contratado con el comisionista que el contrato le pertenece y que toma sobre sí su cumplimiento. La declaración en tal caso, dejando subsistentes las relaciones establecidas entre el comisionista y los terceros, constituirá al comitente fiador de los contratos que aquél hubiere celebrado a su propio nombre.

Siempre hay que establecer las facultades sino que también las prohibiciones que se vana establecer para que no se genera la responsabilidad.

El comisionado al igual que el mandatario esta obligado a rendir cuentas de su gestión, basado en la norma básica del artículo 2155 del Código Civil.

Y la relevación de rendir cuentas no exonera la mandatario de los cargos que contra el justifique el mandato. No porque haya rendido cuentas se exonera de la responsabilidad y de los cargos que pueda tener en su contra el mandante o comitente.

Al igual que en el mandato, esta comisión tampoco se puede delegar. Estoy contratando a un comisionista porque atendida su expertise y administración de derecho ajeno, para realizar esta comisión de un acto o negocio ajeno y por ende no se puede delegar.

Derechos del comisionado

- 1º. Derecho a que le paguen sus remuneraciones.
- 2º. Derecho a que le provean todos los fondos que sean necesarios para el ejercicio de la comisión.
- 3º. Derecho de que le devuelvan o reembolsen todos los gastos en que ha incurrido para ejecutar esta comisión.

Extinción de la comisión

1º. Revocación

Básicamente se extingue por las mismas maneras que hemos conversado y que establece el Código Civil para la extinción del mandato establecidos en los artículos 2163 y ss del Código Civil.

Es decir por mutuo acuerdo, haberse agotado el plazo, etc. Pero con la salvedad del artículo 241 del CdC, porque se establece que no se puede revocar un mandato por parte de quien lo confirió cuando este mandato ha sido aceptado y beneficia a un tercero o interesa al propio comisionista.

Sin perjuicio de esto, si es que no ha sido aceptado o no interesa al comisionista, si se podría revocar.

2º. Renuncia

También se puede extinguir por la renuncia del comisionista pero debe darle tiempo necesario al comitente para efectos de que nombre o tenga a la persona sustituta.

3º. La muerte

La muerte es causa de extinción del mandato. Ahora, de conformidad a lo dispuesto en el CdC la comisión no termina por la muerte del comitente, porque se trata de cumplir varias operaciones determinadas y no se puede terminar.

Distinta a la situación de que se muere el comisionista, porque el encargo es personal y ya no lo podrá delegar.

Con esto terminamos la parte genérica del derecho comercial.